



**Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC**

ILICITUD SUSTANCIAL

Para tal fin, debe tenerse en cuenta que el bien jurídico tutelado en el derecho disciplinario es la función pública, su buena marcha y el cumplimiento de los principios señalados en el artículo 22 de la citada norma, del que se puede extraer que es deber de todo servidor público sujetar su función a asegurar la prevalencia del interés general, a la defensa del ordenamiento jurídico, a realizar solamente aquello que les está permitido, de donde surge su responsabilidad con ocasión de la vulneración de los principios de legalidad, transparencia, honradez y lealtad, o por abusar de sus derechos, o por incumplir sus deberes y prohibiciones, o por incurrir en las causales de inhabilidad, incompatibilidad y conflicto de intereses, o por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, los servidores públicos se comprometen a cumplir con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, lo que significa que la realización de comportamientos expresamente prohibidos o calificados como atentatorios del ordenamiento Jurídico, sin justificación alguna, pueden resultar violatorios de su deber funcional expresamente definido.

Dependencia:	Subdirección de la Investigación Disciplinarias
Número del Proceso:	1704-01-2013-151
Número y fecha del fallo:	RESOLUCIÓN No. 17317-00002 del 09 de marzo de 2018
Asunto:	Fallo de primera instancia
Criterio de selección:	Declarar la Responsabilidad Disciplinaria

RESOLUCIÓN No. 17317-00002 del 09 de marzo de 2018

**POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL
PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2013-151**

1. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Concluida la investigación disciplinaria tramitada en el proceso administrativo disciplinario 1704-01-2013-151, el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC, procede a proferir fallo de primera instancia, conforme a las exigencias del artículo 170 de la Ley 734 de 2002 y de acuerdo con lo que sigue.

2. CONSIDERACIÓN PREVIA

Previo al estudio y análisis del material probatorio obrante, el Despacho se pronunciará sobre las nulidades presentadas por la abogada XXXXX y allegadas dentro de su escrito de alegatos de conclusión radicado el 10 de enero de 2018¹, a través del cual da cuenta de presuntas irregularidades que a su juicio, pudieron afectar el derecho a la defensa y el debido proceso. Estas afirmaciones, se basaron en lo siguiente:

1. *Mediante auto No. (sic) de fecha 5 de julio de 2017, se resolvió las solicitudes probatorias y además dispuso negar el incidente de nulidad propuesto en el escrito de descargos por mi representada.*
2. *... la señora XXXXX, confirió poder especial, amplio y suficiente a la Dora(sic) XXXXX, poder que fue presentado ante su despacho, mediante escrito de **fecha 13 de julio de 2017**, con el que se informó además de la dirección de notificaciones de la referida apoderada, de ello da fe el stiker (sic) con No. De radicado 1-2017-004153.*
3. *... mediante Despacho comisorio de fecha 7 de junio de 2017, se remitió el auto de 6 de julio de 2017, a la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, para que se efectuará la notificación personal a la disciplinada; se tiene además que el mismo fue despachado el 12 de julio, pues así lo registra el folio 215.*
4. *El despacho comisorio fue devuelto junto con las diligencias de notificación por parte del Director Seccional de Aduanas de Barranquilla el 17 de julio de 2017 y recibido por el Despacho investigar en fecha 18 de julio de 2017, y aquí ha de resaltarse que siendo un hecho que la Investigada hizo uso del derecho consagrado en el numeral 2 del artículo 92, no se efectuaron las labores pertinentes para que en termino (sic) se reconociera personería jurídica a la apoderada y se le notificaran las decisiones adoptadas a su defensora, en especial, la que registro mediante el auto referido en párrafos anteriores, que contenía además la negativa de una solicitud de nulidad, desconociendo así, el derecho de defensa técnica, violentando de manera tajante las disposiciones contenidas en el artículo 17 de la Ley 734 de 2002...*
5. *Ahora bien, debe además puntualizarse que tan solo hasta la fecha del 9 de agosto de 2017, mediante auto No. 17417-00359, se le reconoció personería para actuar a la Dr. xxxxx.*
6. *Debe entonces, decirse además, que su despacho (sic) no dispuso de las diligencias pertinentes para efectuar la notificación de la decisión que resolvió negar la solicitud de nulidad, a la entonces apoderada de confianza de la disciplinada XXXXX, como tampoco reposa dentro del expediente constancia de notificación alguna*
7. *Sin embargo, dentro de las piezas procesales no se encuentra la constancia de ejecutoria, como tampoco que su despacho (sic) hubiese efectuado notificación alguna a la apoderada de confianza, situación que flagrantemente vulnera el derecho de defensa y el debido proceso de mi representada, por cuanto habiendo esta nombrado en debida forma su defensor de confianza en fecha 7 de julio de 2017, tan solo y previa solicitud elevada por la abogada de turno, tan solo hasta la fecha del 9 de agosto de le reconoció personería jurídica.*
8. *...La inobservancia en la que incurrió su despacho (sic), al omitir notificar la decisión que a todas luces era susceptible de recurso de reposición, a la apoderada de confianza de la señora XXXXX, constituye una flagrante violación al derecho de contradicción, que se encuentra*

¹ Ver folio 431

inmerso en el de defensa y que además esta elevado a rango constitucional, pues ha de decirse que la defensa técnica prevalece y sería inaceptable, tan siquiera pensar o inferir que mi representada tuvo la oportunidad de alegarlo, por cuanto con antelación había nombrado su defensa de confianza.

*9. ... de manera omisiva desconoció el poder especial, amplio y suficiente conferido en su momento por la disciplinada a la abogada de confianza XXXXX, quien desde ese mismo **7 de julio de 2017**, cuando su despacho conoció su designación, debió realizar las diligencias pertinentes para que se efectuara la notificación de la decisión, máxime cuando se libró despacho comisorio con destino a la Dirección Seccional de Aduanas de barranquilla (sic) para que se efectuara la notificación del auto interlocutoria (sic) aquí discutido tan solo hasta el 12 de julio de 2017, fecha posterior a la presentación del poder por parte de la defensora en las instalaciones de su despacho (sic)*

10. De otra parte , a la causal 3 que introduce el artículo 143 de la Ley 734 de 2002, esto es las irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso, se tiene que la falta de notificación del auto 17424-00013 del 5 de julio de 2017, el cual fue remitido a la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla en fecha 12 de julio de esa calendada (ver folio 215), y del cual no registra dentro de la actuación constancia ni de notificación, ni de ejecutoria, invalida la actuación disciplinaria frente a la decisión adoptada, pues está probado que para la fecha la disciplinada había otorgado poder especial, amplio y suficiente a la Dra. XXXXX, que el mismo fue allegado en legal forma ante su despacho (sic) en fecha 7 de julio de 2017 y que tan solo hasta la fecha 9 de agosto se le reconoció personería para actuar, omitiendo efectuar en debida forma la notificación del Auto interlocutorio que era susceptible de recurso.

Conforme a estas circunstancias, el Despacho abordará el estudio de los planteamientos nulitorios esbozados por la defensa, desde la óptica de las causales contenidas en los numerales 2° y 3° del artículo 143 del C.D.U.

Plantea inicialmente la defensora de confianza, que existen irregularidades de los actos de notificación del auto **No. No. 17424-00013 del 5 de julio de 2017**. Menciona que no existe evidencia de publicidad de la actuación; que la falta de ejecutoria vicia el fin del acto administrativo; indica la presunta violación del derecho de defensa, por cuanto no se le reconoció personería para actuar a la abogada XXXXX, hecho que según la defensa, se agrava al no tener oportunidad de presentar un recurso de reposición. De igual manera, que este Despacho no adelantó acciones pertinentes para hacer la notificación del contenido del auto a la profesional del derecho que para esa fecha fungía como apoderada. En el sentir de la doctora XXXXX, estos temas son determinantes en cuanto a las oportunidades procesales para ejercer la defensa de la señora XXXXX.

En lo que concierne a la falta de evidencia de la diligencia de notificación del Auto que resolvió las pruebas presentadas en descargos y las nulidades allí referidas, el Despacho debe indicar, que conforme con contenido de la constancia secretarial fechada **24 de enero de 2018**, se allegaron los respectivos soportes del Despacho Comisorio **17430-136 del 7 de julio de 2017**, documentos remitidos por la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla mediante oficio **1-87-000-201-366 el 17 de agosto de 2017**. Sin embargo, el oficio remisorio contenía un error mecanográfico, puesto que el expediente de referencia era el **1704-00-20143-151**, radicación diferente a la del presente plenario, por tanto, hasta la fecha de suscripción de la constancia, se contó con esta documentación dentro de este proceso.

Así las cosas, es claro que no se encontró una constancia o acta de notificación personal, toda vez que el acto de la publicidad se llevó a cabo de manera supletoria, actuación realizada al tenor de lo dispuesto en los artículos 103 y 105 del CDU, tal como se explica a continuación:

Mediante con el oficio No. **187-000-201-342 del 4 de agosto de 2017**, se libró citación para comparecer a la funcionaria XXXXX, con el fin de surtir la notificación del Auto que resolvió las nulidades y pruebas en descargos, este documento, fue recibido por la investigada el mismo día de su emisión, resultando entonces, en que a partir de del día siguiente contaba con 3 días para presentarse y en caso de no hacerlo, se procedería a realizar la publicidad de manera supletoria, desarrollo procesal conforme a la normatividad que regula estas actuaciones en el CDU.

En efecto la notificación supletoria fue realizada mediante el **Estado No. 004 del 11 de agosto de 2017** (7 días calendario después y 3 días hábiles siguientes), lo que indica que, la publicidad del mentado auto se cumplió a cabalidad y en debida forma, conforme lo ordenado por la Ley y con el sujeto procesal reconocido por autos a la fecha de proferir la decisión, es decir, al 5 de julio del año inmediatamente anterior.

Por lo anterior, se desestima la acusación relacionada con la falta de notificación del Auto No. 17424-00013 del 7 de julio de 2017, en tanto la publicidad del acto administrativo se realizó en debida forma, toda vez que realizada la citación a la funcionaria, fue ella quien decidió no presentarse de manera personal a surtir la diligencia de notificación, lo que conllevó, a que una vez agotado el término, se fijara un estado conforme a lo establecido en el artículo 105 del CDU.

Ahora bien, respecto a la irregularidad denunciada por la defensora, respecto a la ejecutoria de la decisión, entendiendo que menciona la falta de una constancia para validar la no presentación de un recurso; esta oficina de investigaciones disciplinarias trae a colación lo expuesto en el artículo 110 del CDU: *“Contra las decisiones disciplinarias proceden los recursos de reposición, apelación y queja, los cuales se interpondrán por escrito, salvo disposición expresa en contrario...”* (subrayas propias), por tanto, tratándose de una decisión susceptible a contradicción, operó lo reglado en el artículo 110 de la Ley 734 que dice: *“...Los recursos de reposición y apelación se podrán interponer desde la fecha de expedición de la respectiva decisión hasta el vencimiento de los tres días siguientes a la última notificación...”* (subrayas y negrillas propias). Estas disposiciones que, de acuerdo con los hechos en el proceso de notificación aludido en párrafos anteriores, resulta en lo siguiente:

Teniendo en cuenta que la investigada recibió la citación a notificar el **4 de agosto de 2017** y su renuencia a comparecer, se fijó Estado el **11 de agosto de ese calendario**, luego entonces, tuvo hasta el **16 de agosto** para presentar su recurso. Por consiguiente, al tratarse de una ejecutoria de origen legal, no es necesaria la formalidad de una constancia para dar fe de la no presentación de un recurso, basta ver que no reposa en el expediente radicado posterior a esa fecha, que bien se pudo remitir por correo electrónico o correo físico, prefirió guardar silencio respecto a las decisiones notificadas.

Adicionalmente, aun cuando ya existía decisión reconociendo personería para actuar a la abogada XXXXX, la defensora no se opuso a las decisiones consignadas en el Auto que resolvió nulidades y pruebas en descargos, recordando que, pudo presentar el recurso de reposición a que hubiere lugar o presentar una nueva solicitud para anular la actuación, contrario sensu, no hubo actuaciones respecto a lo contenido en el acto administrativo No. No. 17424-00013 del 5 de julio de 2017.

Por otro lado, la doctora XXXXX alude la presunta violación del derecho de defensa, al no reconocer personería para actuar a la abogada XXXXX, acusando que radicó poder el **13 de julio de 2017** y solamente hasta el **9 de agosto** fue reconocida la personería para actuar. En tal sentido, refiere la nueva apoderada de confianza, que no se le permitió a la doctora XXXXX, controvertir la decisión del **5 de julio de 2017**.

En este sentido, si bien a la profesional del derecho no se le reconoció personería dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación del poder, tal situación no afectó ninguno de los derechos que le asistían dentro de la actuación.

En la misma línea, es preciso acotar que, si bien el Auto del **5 de julio de 2017** no ordenó notificar a la defensora, esto es concordante con el orden cronológico con la expedición de los documentos, determinando entonces que a la fecha de radicación del poder, esta Administración desconocía la existencia del mismo, puesto que, aun identificando que el documento tiene fecha de presentación personal el 23 de junio de 2017², solamente se presentó ante esta Entidad el 13 de Julio de la anualidad anterior y quedó registro en el sticker No. 1-2017-004153³.

Lo anterior, resulta en que este Despacho desestime estas afirmaciones para decretar una nulidad, ya que, como se encuentra probado dentro del expediente, la profesional del Derecho contaba con las facultades para actuar dentro del mismo, sin embargo, optó por validar las actuaciones, lo que hace que esta Subdirección, desestime este argumento como causal de nulidad.

Consecuencia de lo expuesto, conforme a la desestimación de las explicaciones de la defensa, este Despacho no encuentra elementos para decretar una nulidad, acción que, conforme a lo estipulado en el artículo 135 del Código General del Proceso debe reunir unas características tales como: ***artículo 135: Requisitos para alegar la nulidad “...No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omitió alegarla como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla”***, adicionalmente el ***artículo 136 del CGP dispone: Saneamiento de nulidad: la nulidad se considerará saneada en los siguientes casos: 1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente y actuó sin proponerla...***” (Subrayado propio).

Por lo tanto, en cuanto a los requisitos para alegar la nulidad, la abogada actuó dentro del proceso en forma posterior, de tal forma que, las pruebas solicitadas por la investigada y decretadas en su totalidad mediante el auto No. 17424-00013, fueron practicadas conforme al cronograma presentado por la defensa, puesto que mediante correo electrónico del 16 de agosto de 2017⁴, informó que **SOLAMENTE** disponía de fechas libres en el mes de octubre de ese calendario, momento en el cual pudo alegar la presunta nulidad, sin embargo guardó silencio. Ahora, en razón al saneamiento de la nulidad, si bien se tiene para presentarlas hasta antes de proferir el fallo definitivo⁵, no es menos cierto que pudo proponerlas antes de llegar a la etapa de alegatos.

Concordante con las normas aludidas y analizadas bajo los hechos alegados como irregulares por la defensa, se demuestra que este Despacho actuó con la debida diligencia para garantizar siempre el derecho al debido proceso, a la defensa y de contradicción, de tal forma que las diligencias probatorias decretadas, así como las actuaciones posteriores, fueron de conocimiento de los sujetos procesales, circunstancias que se pueden evidenciar en los testimonios recibidos y en las copias entregadas respecto a las pruebas gestionadas, en tal razón, no prospera la nulidad.

² Ver folio 220.

³ ver folio 219.

⁴ Ver folio 238.

⁵ Artículo 146 de la Ley 734 de 2002.

Análisis que, permiten a este Despacho citar lo señalado por el Consejo de Estado en Sentencia del 26 de julio de 2012⁶, en el cual expreso:

“De igual modo, se puede afirmar que no toda irregularidad dentro del proceso disciplinario genera por sí sola la nulidad de los actos a través de los cuales impone a un funcionario una sanción, pues lo que interesa en el fondo, y tal y como advirtió al iniciar las consideraciones, es que no haya incurrido en faltas que impliquen violación del derecho de defensa y del debido proceso. En otras palabras, sólo las irregularidades sustanciales o esenciales, que impliquen violación de garantías o derechos fundamentales, acarran la anulación de los actos”.

Conforme a las razones anteriores, no hay virtud para declarar la nulidad propuesta por la defensa, por consiguiente, entrará el Despacho a pronunciarse sobre el fondo del asunto objeto de juicio, con base en los planteamientos presentados en los alegatos de conclusión y en el análisis ponderado de las pruebas legal y oportunamente allegadas al expediente.

Así las cosas, habrá que indicar inicialmente, que este operador disciplinario no encuentra vocación de prosperidad a la solicitud de nulidad por supuesta violación al derecho de defensa, en la medida, que contrario a lo sostenido por la defensa, el Despacho ha cumplido con lo establecido en las normas y ha guardado un respeto por el principio de buena fe procesal. Los sujetos procesales han tenido total acceso a la actuación, a solicitar, aportar y controvertir las pruebas e intervenir en su práctica, a interponer los recursos de ley y a presentar las solicitudes necesarias para garantizar la legalidad de la actuación disciplinaria, al tenor de lo consignado en el artículo 92 de la Ley 734 de 2002 y demás normas concordantes.

3. IDENTIDAD DE LA INVESTIGADA

XXXXX, identificada con cédula de ciudadanía XXXXX de Barranquilla, ingresó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -**DIAN**- el 11 de marzo de 2008; para la época de los hechos, se desempeñaba como Facilitador IV Código 104 Grado 04 Adscrita a la División de Gestión de la Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla⁷.

4. HECHOS

Mediante oficio No. 1.87.000.201.0441 del 17 de mayo de 2013⁸, suscrito por el entonces Director Seccional de Aduanas de Barranquilla (Atlántico), se informó de la comisión de presuntas irregularidades en desarrollo de un procedimiento de control aduanero, concretamente, lo registrado en el Acta de Inspección No. 000050 elaborada por la funcionaria **XXXXX**.

Se indicó que, al parecer, la funcionaria antes mencionada efectuó diligencia de inspección al equipaje no acompañado asociado a la guía aérea número **72989014730** de fecha 27 de abril de 2013, a nombre de la señora XXXXX, señalando en el acta se trataba de *“efectos personales perfume ropa usada”*, lo que no daba lugar al pago de impuestos, ante lo cual procedió el levante No. 872013M2000000001.

Posteriormente, funcionarios del Grupo de Carga de la División de Gestión de Operación Aduanera en compañía del Grupo de Apoyo Técnico Operativo (GATO), hicieron presencia en las instalaciones de la empresa TAMPA CARGO S.A., ubicada en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de la

⁶ Consejo de Estado, expediente 110010325000201000271 del 26 de julio de 2012, C.P. doctor Víctor Hernando Alvarado Ardila.

⁷ Ver folio 105.

⁸ Ver folio 2.

ciudad de Barranquilla, realizando reconocimiento físico de la mercancía amparada con la documentación antes citada, detectando que los elementos allí encontrados no correspondían con los relacionados por la funcionaria en el acta de inspección indicada.

Adicional a lo anterior, se indicó no debió otorgarse levante a las mercancías, ya que existía incongruencia con lo denominado “efectos personales perfume ropa usada”, por cuanto se trata de elementos de cocina respecto de los cuales debió efectuarse la liquidación del 15% por concepto de impuesto único *ad valorem*.

5. CARGO FORMULADO

Por medio del Auto No. 17406-0007 del 16 de marzo de 2017⁹, esta Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la UAE ITRC, formuló pliego de cargos a la investigada XXXXX, del siguiente tenor:

PRIMER CARGO:

La señora **LUZ JANETH DEL TORO ACOSTA**, abusando de su cargo y funciones como Facilitador IV, código 104 grado 04, adscrita a la División de Gestión de Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, presuntamente favoreció en forma deliberada el ingreso de bienes al territorio nacional, al haber otorgado levante No. 872013M2000000001, sobre las mercancías señaladas en la guía aérea 72989014730 de fecha 27 de abril de 2013, que corresponde a la mercancía descrita en la factura No. 43001 del 12 de mayo de 2012, a nombre de XXXXX, a través de una modalidad de importación improcedente y sin liquidar los impuestos correspondientes.

Con el comportamiento antes descrito, la señora **XXXXX**, pudo incurrir en falta disciplinaria, de conformidad con lo señalado en el numeral 44 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que reza:

<<**ARTÍCULO 48. SON FALTAS GRAVÍSIMAS LAS SIGUIENTES: (...) NUMERAL 44.** Favorecer en forma deliberada el ingreso o salida de bienes del territorio nacional sin el lleno de los requisitos exigidos por la legislación aduanera>>

Lo anterior considerando que, la conducta mostrada por XXXXX, pudo vulnerar la legislación aduanera, pues consintió el ingreso de mercancía por una modalidad de importación improcedente (viajeros), además de incumplir requisitos legales, específicamente los consagrados en los Artículo 208 y 209 del Estatuto Aduanero vigente para la época y que corresponden a equipaje con pago de tributo.

<<**ARTICULO 208. EQUIPAJE CON PAGO DE TRIBUTO ÚNICO.** <Artículo derogado a partir del 22 de marzo de 2016, por el artículo 676 del Decreto 390 de 2016> Los viajeros que ingresen al país y acrediten una permanencia mínima en el exterior de cinco (5) días calendario, tendrán derecho a traer como equipaje acompañado o no acompañado, sin registro o licencia de importación y con el pago del tributo único de que trata el artículo 209 del presente Decreto, hasta tres (3) unidades de cada uno de los siguientes bienes: artículos de uso doméstico sean o no eléctricos, artículos deportivos y artículos propios del arte u oficio del viajero, hasta por un valor total de dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 2.500) o su equivalente.

PARAGRAFO 1o. Los viajeros que se acojan a lo dispuesto en el presente artículo mantienen el derecho a la franquicia contemplada en el artículo anterior en la cuantía allí establecida.

PARAGRAFO 2o. No hará parte del equipaje el material de transporte comprendido en los Capítulos 86, 87, 88 y 89 del Arancel de Aduanas. Se exceptúan de lo anterior, los accesorios para vehículos y las mercancías que clasifiquen por las siguientes subpartidas arancelarias:

87.12.00.10.00 Bicicletas para niños

⁹ Ver folios 169 a 176.

87.12.00.20.00 Las demás bicicletas

87.12.00.90.00 Los demás velocípedos

87.13.10.00.00 Sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos, sin mecanismo de propulsión

87.13.90.00.00 Los demás sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos, incluso con motor u otro mecanismo de propulsión

87.15. 00.10.00 Coches, sillas y vehículos similares para transporte de niños.

PARAGRAFO 3o. La introducción de las mercancías señaladas en este artículo sólo podrá efectuarse por una misma persona, una sola vez cada año>>.

<<ARTICULO 209. LIQUIDACIÓN Y PAGO DE TRIBUTOS ADUANEROS POR CONCEPTO DE LA IMPORTACIÓN DE EQUIPAJES DE VIAJEROS. <Artículo derogado a partir del 22 de marzo de 2016, por el artículo 676 del Decreto 390 de 2016> De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 1742 de 1991, las mercancías que vengan en el equipaje de los viajeros provenientes del exterior y que no gocen de franquicia de gravámenes pagarán un tributo único del quince por ciento (15%) ad valorem.

El pago deberá efectuarse en los bancos o entidades financieras autorizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ubicados en los puertos o aeropuertos de arribo del viajero al territorio aduanero nacional>>

SEGUNDO CARGO:

La señora XXXXX, abusando de su cargo y funciones como Facilitador IV, código 104 grado 04, adscrita a la División de Gestión de Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, extendió documento público ideológicamente falso, a saber el “AUTO Y ACTA DE INSPECCIÓN” PARA EQUIPAJES NO ACOMPAÑADOS número 000050 del 29 de abril de 2013, donde registró información falsa y otorgó levante a la mercancía con cuyo documento ingresó la viajera XXXXX en su declaración de equipaje formato No.530817964262 4 fechado el 31 de marzo de 2013

Conducta que, a criterio del despacho, se encuentra tipificada en el Código Penal, bajo el tipo penal de falsedad ideológica en documento público, de acuerdo con el artículo 286 de dicha norma, que señala:

<<ARTICULO 286. FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO. El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años.

Por razón de la tipificación penal antes citada, el despacho considera que el comportamiento desarrollado por XXXXX, se enmarca en la falta disciplinaria del numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que señala:

<< ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS: Son faltas gravísimas las siguientes:
1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo ...>>

**6. ARGUMENTOS DE DEFENSA:
VERSIÓN LIBRE, DESCARGOS Y ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

6.1. VERSIÓN LIBRE Y ESPONTÁNEA:

Pese a los esfuerzos y medios puestos a disposición por la Subdirección, la disciplinada se abstuvo de materializar el derecho consagrado en el numeral 3º del artículo 92 de la Ley 734 de 2002.

6.2. DE LOS DESCARGOS:

XXXXX, en su calidad de investigada y dentro de los términos legales para hacerlo, presentó su escrito de descargos ante la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla el día 18 de abril de 2017¹⁰, calificando de inadmisibles las imputaciones en cuanto a las conductas consideradas como infracciones disciplinarias, pues, en su sentir, el material probatorio recaudado a lo largo del plenario no demuestran las infracciones disciplinarias y lo correcto era la terminación de la actuación.

El punto de partida en su defensa está direccionado al supuesto abuso de su cargo para materializar un favorecimiento en forma deliberada de bienes al territorio nacional, destacando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Penal, conforme a la cual se podría presentar un abuso del cargo siempre y cuando implique un desborde a la restricción de límites o cuando se utilizan en forma proterva¹¹. En este sentido, no incurrió en abuso de función o cargo porque en ningún momento desborde, restringió o empleó arbitrariamente el mismo con propósitos ilícitos, al igual que las atribuciones conferidas legal o reglamentariamente, como quiera que no hizo un uso indebido o ilegítimo del cargo, como tampoco intimidó al ciudadano con el fin de obtener un pago por ello.

Respecto al ingreso de bienes al territorio nacional, justificó su acción en una descripción de las circunstancias del equipaje no acompañado, entre las cuales, destaca se hizo por un lugar habilitado (Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz); se amparó con el documento de transporte denominado *Guía Aérea* No.72989014730 del 27 de abril del 2013¹²; que contaba con sus documentos soporte tales como: factura No. 4001 del 12 de mayo de 2012¹³, expedido por el proveedor por la suma de USD \$1.335,00 a nombre de XXXXX; lista de empaque No. WR 0020057472 del 25 de abril de 2013¹⁴ expedida por la empresa **WAREHOUSE RECEIPT**, documentos debidamente mencionados en el artículo 121 del Decreto 2685 de 1999.

En cuanto a la modalidad de importación, señaló que la señora XXXXX tenía derecho a traer la mercancía por cumplir con los requisitos de estadía fuera del país, para lo cual trajo a colación el formulario No. 5308179642642-4 del 21 de marzo de 2013¹⁵, conforme al cual la viajera no llevaba todo su equipaje en ese momento y la Guía Aérea No. 72989014730 del 27 de abril de 2013, no cabe dentro de la perspectiva del artículo 208 del Decreto 2685 de 1999, porque “...*este aplica, se refiere al ingreso de mercancías, que reúnan los siguientes requisitos...*” en ese sentido transcribió lo estipulado en la norma aduanera, y afirma que dichas piezas se deben ver como un todo y no de manera individual, razón por la cual no se debe aplicar el parágrafo 2 del artículo 208 del Estatuto Aduanero por cuenta de la exclusión expresa de este tipo de mercancía.

En lo que corresponde a la omisión del cobro del impuesto o tributo único, la disciplinada citó lo mencionado en el artículo 209 del Decreto 2685 de 1999, por cuenta de la liquidación y pago de tributos aduaneros, resaltando que los **que no gocen de franquicia de gravámenes pagarán un tributo único del quince por ciento (15%) ad valorem** (Negritas de la encargada).

¹⁰ Ver folio 190.

¹¹ Ver folio 192.

¹² Ver folio 12.

¹³ Ver folio 17.

¹⁴ Ver folio 51 del cuaderno Anexo No. 1

¹⁵ Ver folio 26.

Finalmente, sobre este cargo, menciona que la modalidad de importación si era procedente, por cuenta de las exclusiones legales mencionadas en el artículo 208 parágrafo 2°, ya que en las mismas no se encuentran relacionados los elementos que conforman la cocina; sin embargo, hace una mención sobre la forma en la cual se ordenó la entrega parcial de la mercancía, señalando que de haber ingresado ilegalmente el capitán XXXXX no hubiese resuelto de tal forma la situación jurídica de la mercancía aprehendida.

Respecto del segundo cargo, la señora XXXXX indicó el Despacho actuó parcializado toda vez que no se realizó ningún análisis de la referida acta y auto de inspección, pues no se tuvo en cuenta lo advertido en diligencia especial, esto es, un supuesto problema en el equipo de cómputo que generó la falla traducida en la falsedad ideológica, ya que la mencionada acta es un modelo llevado por el grupo para el 13 de abril de 2013, donde si bien se registraron los datos correspondientes, por error en la plantilla quedaron los datos del anterior equipaje no acompañado, tal como se corrobora con los errores observados en las casillas 23 y 32 del acta, donde se encuentra información errada del número de declaración y recibo oficial de pago, además de la fecha de cada documento anterior y, en la casilla correspondiente al valor, se dejó consignado USD \$1.788,87; en la casilla 29 y 39, también se presentaron errores en su contenido; a partir de lo cual concluye la disciplinada, se trató de un error por cuenta del modelo manejado por sistema que mantuvo las características de otra acta diligenciada con anterioridad.

Esta situación fue expuesta en diligencia del 18 de septiembre de 2013¹⁶ por el entonces Coordinador del Grupo de Viajeros, donde mencionó que el acta presenta errores o inconsistencias al haberse realizado el diligenciamiento de la plantilla sobre otra tramitada previamente y, por ello, no guardó los cambios y mantuvo la información original, afirmación resaltada por la señora XXXXX atribuyéndolo a un error por falta de inducción sobre el sistema donde registró incongruencias, producto de la presión que ejercía el Director Seccional de Aduanas de Barranquilla y sumado al hecho de estar en embarazo para la época, tal como fue advertido por la señora XXXXX en su escrito de reconsideración, radicado con razón a la aprehensión de la mercancía.

Por lo expuesto, concluye XXXXX que en ningún momento tuvo la intención ni la voluntad de cometer un acto ilícito, el cual, para la investigada, sería descalificado por cuenta del lleno de los requisitos para llevar a buen recaudo el ingreso del equipaje no acompañado.

En otro tópico, ya apartada de la defensa de los cargos imputados, hizo un análisis sobre el proceso llevado en contra de la señora XXXXX con ocasión del decomiso de la mercancía importada como equipaje no acompañado, indicando se cambió el valor de la mercancía indebidamente y prueba de ello es la factura comercial No. 43001 del 13 de diciembre de 2012, documento soporte valido y expedido por el proveedor, lo que permite aseverar que se encuentra dentro de los parámetros de legalidad en cuanto a forma, valor y cantidad, por tanto *“el valor aplicable el excesivo valor se señaló, valor que se acostumbraba a colocar a los decomisos de MERCANCÍAS en épocas del capitán CASTILLO SANTOS, para inflar su gestión”*. El precio asignado a la mercancía hizo que se sobrepasara, desconociendo las características de la misma, el hecho de ser producto en promoción no reembolsable, hechos responsables del valor en la factura aludida por la funcionaria, superando claramente la cantidad permitida y contemplada en la norma aduanera.

6.3. DE LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

¹⁶ Ver folios 111 al 115.

Fueron presentados por la apoderada de confianza a quien fue sustituido el mandado otorgado por la disciplinada¹⁷, profesional que en la parte inicial del escrito hizo mención a los hechos origen de la presente causa disciplinaria, para posteriormente demandar la nulidad resuelta al inicio de esta decisión, por lo que se relacionará a continuación los argumentos diferentes a estos puntos.

En cuanto a los hechos, la profesional del Derecho indicó que mediante Auto No. 17403-116 del 30 de mayo de 2013, se ordenó la apertura de indagación preliminar en contra de su representada, por encontrar reunidos los requisitos de competencia y menciona *“...de entrada señaló que la conducta de mi mandante se adecuaba a la descripción típica consagrada en el artículo 48 de la Ley 734 de 2002, norma en blanco que remite a la Ley 600 de 2000 (sic), en lo atinente al delito de falsedad ideológica en documento público”*.

Seguidamente, hizo una narración sobre las pruebas practicadas dentro del plenario, destacando que la declaración de viajeros **No. 5308179642624** diligenciada por XXXXX, donde se registró que la viajera no ingresaba con todo su equipaje era ilegible en su reverso, en lo que respecta a la descripción de la mercancía; del resto del material probatorio no realizó comentarios.

Ahora bien, sobre los cargos imputados resaltó la defensora que el Despacho desconoció los puestos de trabajo ocupados por su mandante durante su vinculación a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y en especial la ausencia de capacitación impartida por la entidad, para lo cual hace alusión al extracto de historia laboral. Del mismo modo, proclamó un desconocimiento al principio rector de presunción de inocencia, ya que en su consideración la calificación provisional se realizó sin pruebas que respaldaran la acusación y se partió de la mala fe en el actuar de su prohijada, pues lo único que soporta las imputaciones son presunciones en cuanto a los elementos constitutivos del dolo, violentando de esa manera el principio de buena fe y demás garantías constitucionales¹⁸.

Como soporte de sus afirmaciones trae a colación lo reglado por el CDU sobre la presunción de inocencia, concretamente en el artículo 9 de la Ley 734 de 2002, concluyendo siempre deberá presumirse inocente al investigado hasta que no se declare su responsabilidad en fallo debidamente ejecutoriado, por lo que cuestionó algunas expresiones del auto de cargos que consideró lesivas de este principio, además de exigir un proceso garantista y sometido a las leyes vigentes al momento de realizar la conducta disciplinaria, protegiendo los derechos del disciplinado.

Posteriormente, realiza un recuento de las pruebas practicadas en descargos, sobre las cuales, hace comentarios respecto al acta de aprehensión, destacando que si bien es cierto resulta ser un acto administrativo, este no es definitivo, constituyéndose en un acto de mero trámite y conforme a las disposiciones aduaneras vigentes para la época de los hechos, esta puede ser objetada por el interesado o quien tenga legitimidad en la causa para hacerlo, de conformidad con las previsiones del artículo 512 del estatuto aduanero¹⁹.

Avanza la profesional del derecho a los documentos soporte de la importación, mencionando que el equipaje no acompañado estaba amparado por la factura comercial de la marca **VIKING** por un valor de USD \$ 1.335 dólares, presentada ante autoridad aduanera mediante manifiesto de carga **No. 116575004279548** y amparada en la guía aérea **No. 72989014730**. Acto seguido, se refiere al acta de aprehensión **97-00494 FISCA** del 8 de mayo de 2013, mediante la cual se dispuso la

¹⁷ Ver folios 431 a 446.

¹⁸ Ver folios 436.

¹⁹ Ver folios 440.

aprehensión de la mercancía por la causal 1.6.²⁰, mencionando que el inspector de turno dejó de lado la factura comercial que soportaba la compra de la mercancía y traía inmerso el valor que la usuaria aduanera había cancelado por la misma y haciendo caso omiso a ello (es decir del valor y/o valor de referencia), de manera apresurada dispuso su avalúo buscando precios de referencia y/o estimados a través de páginas de internet²¹.

En lo que respecta a la viajera XXXXX, alude y transcribe partes del documento a través del cual objeto la aprehensión que fuere objeto su mercancía, señalando aspectos como el alto estado de embarazo de **XXXXX**; los desplazamientos al lugar donde se encontraba la mercancía; los fundamentos de derecho y los errores en los cuales incurrió la administración al momento de diligenciar el Acta No. 000050. Así mismo, se refiere al testimonio del señor XXXXX, quien fuera Jefe del GIT informal Viajeros, área en la cual se encontraba adscrita la disciplinada y destacó que: *“En el Grupo Informal Viajeros, había un computador donde se encontraban diseñando o había un modelo de actas de inspección para ser diligenciada por cada uno de los funcionarios una vez que terminaban de hacer el reconocimiento de los equipajes no acompañados de los viajeros, de las cuales se imprimían 3 copias distribuidas de la siguiente manera: uno para el viajero, otro para el deposito donde se encontraba la mercancía y otro para el archivo del grupo”*, además advirtió que para la época de los hechos materia de investigación *“la funcionaria se encontraba en estado de embarazo”*.

A partir de lo anterior, concluye la defensa se encontraba probado el estado de embarazo de su prohijada, hecho sumado a que las instalaciones de **TAMPA** cargo se encuentran fuera de las oficinas del Aeropuerto Ernesto Cortissoz de la ciudad de Barranquilla, implican tuvo que desplazarse más de un kilómetro hacia dicho depósito para efectuar la verificación del equipaje no acompañado, anotando que la investigada se encontraba sola, puesto que en el horario en el cual acudió la señora XXXXX se registraba la llegada de un vuelo internacional, situación que ocupó la atención de sus compañeros y en tal razón debió realizar la inspección sin apoyo.

Aunque la situación de gestión no debe entenderse como enfermedad, su representada cumpliendo el deber funcional se desplazó y realizó la inspección de la mercancía, pese a que la misma se encontraba embalada en cajas que requerían su apertura y revisión, por lo que la defensa no compartió la imputación formulada por el Despacho, ya que, pues a su juicio no existe prueba que comprometa la responsabilidad de su prohijada en hechos producto de una falla del equipo de cómputo donde se diligenció el acta y no se guardaron los cambios efectuados en la plantilla modelo, desvirtuándose el dolo y la intención de favorecer en algún sentido a la usuaria, ya que como se lee de los documentos aportados la información registrada en Acta **No. 000050** correspondía a la de un viajero diferente.

En torno a la supuesta falla manifiesta que el señor XXXXX, entonces jefe del Grupo Informal de Viajeros, relató que en la elaboración del Acta de inspección o reconocimiento del equipaje no acompañado realizado por la funcionaria (**XXXXX**), se presentó un inconveniente técnico, en consecuencia, una vez terminada e impresa el acta, el sistema no guardó los datos o la información que se estaba haciendo en el sistema operativo que funcionaba para esa diligencia. Es decir, se dieron cuenta posteriormente a la impresión, sobre el error en la información que correspondería a la de otro usuario aduanero.

Concordante a esto, puntualiza la defensora los hechos que se investigan y en curso de análisis de culpabilidad, en lo que corresponde a la falta gravísima mencionada en el artículo 48 numeral 44 del CDU no tuvo ocurrencia en los términos referidos en el pliego de cargos, puesto que no existe

²⁰ Ver folio 440

²¹ Ver folio 19 a 26 del Cuaderno Anexo No. 1

prueba que den por sentados los elementos constitutivos del dolo y además porque es claro que en efecto, la conducta desplegada por su mandante, estuvo acompañada por la ocurrencia de un error involuntario que se materializó en la falla del equipo donde se diligenció el acta discutida.

Referente al dolo requerido y calificado en el pliego de cargos, alude un resultado apresurado, descabellado y amañado de la situación, por cuenta de una apreciación errónea de la historia laboral de la disciplinada, omitiendo el histórico de los nombramientos y menos hubo verificación somera de las capacitaciones impartidas a su mandante, quien no estuvo vinculada a la División de la Operación Aduanera GIT Viajeros desde el año 2008 cuando ingresó a la entidad.

Retomando el tema del ingreso de la mercancía, la apoderada hizo mención al testimonio de la servidora de la administración aduanera XXXXX, quien para la época de los hechos se ubicaba en la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla y con ocasión a la designación del expediente **DM 201320130799**, asumió el conocimiento de la solicitud de revocatoria directa presentada en contra de la Resolución de Decomiso **No. 778 del 17 de julio de 2013**.

La señalada declarante, se refirió a que elaboró un proyecto de decisión que tendría la revisión del Despacho del Director Seccional, en ese borrador, se ordenaba la entrega de 3 elementos de los que trajo la viajera, pagando tributo único tal como se lo ordena la norma aduanera, adicionalmente, se ordinaria cambiar la modalidad de importación de acuerdo a la legislación vigente; es proyecto fue revisado en el Despacho por el funcionario encargado, fue aprobado, sin embargo el Director de la época no acepto el proyecto, razón por la cual entregó el expediente al Jefe de la Vía Gubernativa y se lo informó al Jefe de la División Jurídica.

Así las cosas, afirmó se encontraría probado que la disciplinada, jamás tuvo la intención de consignar falsedades en el acta de inspección y auto comisorio²², como tampoco fue consiente de la situación presentada, pues en realidad los datos consignados en el documento que se reprocha disciplinariamente por parte del Despacho, atendieron a situaciones reales, es decir a una operación aduanera registrada anteriormente, y en tal sentido, quedaría probado junto con las manifestaciones de XXXXX y XXXXX, que la situación atendió a un error involuntario de la aquí enjuiciada y no como lo ha venido argumentando esta oficina de investigaciones disciplinarias.

Análisis aparte merece para la defensa, otra faceta de la declaración de la señora XXXXX, en lo que respecta la apreciación sobre el contrabando, ya que, en cuanto a una pregunta directa por parte de la apoderada, la servidora mencionó que no se trataría de contrabando porque *“esa fue una mercancía presentada ante autoridad aduanera y la mercancía presentada a la autoridad aduanera desde ningún punto de vista puede considerarse contrabando, porque si hubiese sido contrabando de ninguna manera yo hubiera proyectado la resolución que decidió la revocatoria, en los términos que se hizo y fue presentada porque existía un documento de transporte”*, en el mismo sentido, la doctora XXXXX le indagó sobre el error de la administración, la funcionaria nuevamente hizo mención a la falla en el computador por cuenta de la información errada que este registro en el formato ya mencionado.

Adicionalmente, hace una mención sobre una declaración de XXXXX, en el sentido de mencionar que alrededor de esa situación pudo percibir un interés personal de parte del Director Seccional de Aduanas de Barranquilla Capitán XXXXX.

Hechas estas precisiones sobre el material probatorio, la representante de nuevo menciona que puede estar presente el error involuntario, puesto que los elementos del dolo para el caso de la

²² Ver folio 444.

imputación, no se configuran en ningún momento y por tanto el sustento del análisis de culpabilidad, al igual que el de ilicitud y tipicidad perdería su estructura y el cargo queda desestimado, entendiendo que debido a las condiciones de su estado de embarazo, los desplazamientos y la forma en que debía verificarse la mercancía, de la cual recuerda se encontraban en cajas embaladas y rotuladas, que requería ser movilizadas y alzadas, de lo cual afirma, su prohijada muy posiblemente no actuó con la diligencia y cuidado que se requería en el momento, sin embargo, ello desplegaría una acción encaminada bajo móviles de dolo y tipificados en la comisión de una falta gravísima²³.

Los argumentos que dan soporte a la teoría del error de la defensa, las valida a través de la doctrina,

en tal caso, haciendo la transcripción de la definición del *Error de tipo culposo*²⁴, con ello, afirmó que la señora XXXXX confió en que el sistema en efecto había guardado el acta en dbida forma y al firmarla sin verificarla y entregarla a la usuaria aduanera quien por lo visto tampoco se percató del error, confió ciegamente de lo que en verdad se había consignado correspondía a la operación aduanera realizada por la señora XXXXX, y no que el sistema tuvo una falla y no guardo los cambios, dejando apartes de la operación aduanera correspondiente a la señora XXXXX.

Concordante con esta tesis, trae a colación otro tratadista, quien menciona las características para referirse a los errores de buena fe y que estos no son disciplinables²⁵, del cual trae una cita textual del contenido de las definiciones y conforme a las mismas, alega que dentro de la foliatura no se infiere, no aflora, no emana el más leve indicio o sospecha que su defendida hubiera desplegado alguna actividad o interés para favorecer el ingreso de mercancías a la mencionada usuaria o desconocer el pago de tributos, máxime cuando con fecha anterior la mercancía se encontraba perfilada para su revisión por parte del grupo GATO.²⁶

De conformidad y de manera congruente con su escrito, menciona la libelista que no se encuentra ninguna prueba certera que pudiese demostrar la responsabilidad disciplinaria de su mandante, por ende, en la misma línea, cita al tratadista **PRIETO ELLERO**, jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la que extrae apartes de la Sentencia del 15 de mayo de 1982 y, finalmente, lo estipulado por el artículo 230 superior, subrayando que la doctrina es criterio auxiliar de la actividad judicial²⁷.

En consecuencia, a los argumentos esgrimidos, precisa que la servidora XXXXX actuó bajo la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria, situación estipulada como causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria por el legislador en la Ley 734 de 2002 en su artículo 28 numeral 6°.

**7. CONSIDERACIONES DE INSTANCIA:
RAZONES DE LA DECISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS EN QUE SE BASA**

7.1. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA:

Este Despacho es competente para proferir el fallo de primera instancia dentro de la presente investigación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con las previsiones del Decreto 4173 del 3 de noviembre de 2011.

²³ Ver folio 445.

²⁴ GÓMEZ LÓPEZ, J.O. (1996) Culpabilidad e Inculpabilidad, Pág 716 El error del tipo culposo

²⁵ GARZÓN VILLEGAS, O. (2003) Práctica Forense Disciplinaria, 1ª Edición, Pág 233

²⁶ Ver Folio 445

²⁷ Ver Folio 447

En atención a lo ordenado en el Artículo 142 de la Ley 734 de 2002, no se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado, cuya apreciación debe corresponder a las reglas de la sana crítica, según lo establece el Artículo 141 ibidem.

De igual manera, deben reunirse de manera conjunta los requisitos de legalidad, ilicitud sustancial y culpabilidad, reglados en los artículos 4, 5 y 13 de la Ley 734 de 2002, los cuales es menester se encuentren debidamente acreditados dentro del sumario a partir de elementos de prueba legalmente allegados al proceso.

7.2. DEL CASO EN CONCRETO

El Despacho entra a valorar a continuación el material probatorio allegado a la presente instrucción disciplinaria, conforme con las reglas de la experiencia, la lógica y la sana crítica, a efectos de adoptar la decisión de fondo que en derecho corresponde.

7.2.1. Pruebas documentales:

- 1. Oficio No. 1-87-000-201-0441 del 17 de mayo de 2013²⁸, suscrito por el Capitán de Fragata XXXXX, Director Seccional de Aduanas de Barranquilla para la época de los hechos, mediante el cual informó la existencia de presuntas irregularidades en el procedimiento de control aduanero de acuerdo con lo registrado en el Acta de Inspección No. 00050 del 29 de abril de 2013, elaborada y firmada por la servidora XXXXX.
- 2. Nota interna No. 0457 del 29 de abril de 2013²⁹, suscrita por el Coordinador del Grupo Informal GAPER, en cuyo asunto se refiere al perfilamiento manifiesto de carga No. **116575004279548** del 27 de abril de 2013 motonave MODO AEREO³⁰. Esta directriz, fue impartida conforme a los artículos 469 y 470 del Estatuto Aduanero vigente para la época de los hechos, de conformidad con los resultados del análisis y perfilamiento del riesgo, información y resultados del P.C.M., para su control.

Dentro de la orden mencionada, en su décima casilla aparece mencionado el documento de transporte No. **72989014730**; carga suelta a nombre de XXXXX; equipaje no acompañado; asignado al grupo de control **GRUPO I.T. Control de Carga y Tránsitos**; lo acompañaría el grupo GATO y sería directo.

- 3. Guía aérea No. **72989014730** del 27 de abril de 2013³¹, equipaje no acompañado a nombre de XXXXX.

Dentro de los documentos que se allegan con la guía, se tienen el manifiesto de carga de llegada aérea del 27 de abril de 2013³², donde en el primer ítem refiere al documento de transporte ya identificado; describe un equipaje no acompañado; contiene 15 piezas; pesa 1243 kilogramos y refleja la información del remitente y destinatario, para este caso los datos de XXXXX CC XXXXX en Barranquilla.

²⁸ Ver Folios 2 a 4

²⁹ Ver folios 5 a 9

³⁰ Ver folios 6

³¹ Ver folios 10 a 15

³² Ver folio 11

El documento de transporte tramitado por **TAMPA CARGO**³³, en la casilla correspondiente a *hanging information* menciona el documento **WR#0020057472 (15 PCS)**, por un total de USD \$ 3,566.90 y con la anotación de descargue directo por la modalidad de importación, cabe anotar que menciona el peso total de 1346 kilogramos que equivalen a 2697 libras, de acuerdo con la información suministrada por el remitente en la guía. A folio seguido, aparece una copia de lo antes referido con el sello de **ALMAGRARIO**³⁴.

Adicionalmente aparece el documento expedido por **O.K. CARGO, CORP**³⁵, empresa que mediante el documento referido consta el contenido de la guía y menciona como equipaje no acompañado efectos personales (electrodomésticos), de acuerdo a la lista de empaque adjunta a la guía y **WR #0020057472**.

4. Factura comercial **No. 43001 del 5 de diciembre de 2012**³⁶ y **No. 43024 del 13 de diciembre de 2012**³⁷ a nombre de XXXXX; la primera por valor de USD \$ 1,159y la segunda por USD \$ 1,335.00.

A estos documentos, les fue anexadas las fotografías³⁸ donde se puede identificar los elementos de una cocina y una lista de los elementos que la conformaban³⁹, es decir, las 15 piezas mencionadas en la guía de transporte.

5. Copia del pasaporte y cédula de ciudadanía de la señora XXXXX⁴⁰.
6. Declaración de Equipaje y título representativo en dinero-Viajeros No. **5308179642624** del 21 de marzo de 2013⁴¹.
7. Acta y Auto de inspección para equipajes no acompañados **No. 00050 del 28 de abril de 2013**⁴².

Se debe advertir de este documento que en el material probatorio se puede evidenciar la existencia de un formato firmado por los intervinientes y con el sello de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, el otro tiene solo la firma de los intervinientes sin el sello de la Administración Aduanera.

8. Acta de diligencia No. **853 del 28 de abril de 2013**⁴³, adelantada por el Grupo de Carga del Aeropuerto Ernesto Cortizos, conforme a la cual se ordenó la aprehensión de la mercancía y se realizaron observaciones sobre las causales de la retención de la mercancía.
9. Acta de aprehensión **No. 87-0049FISCA** del 8 de mayo de 2013⁴⁴, diligenciada por la División de Gestión de Fiscalización

³³ Ver folio 12

³⁴ Ver folio 13

³⁵ Ver folio 14

³⁶ Ver folio 17

³⁷ Ver folio 18

³⁸ Ver folios 19 y 20

³⁹ Ver folios 21

⁴⁰ Ver folios 22 a 24

⁴¹ Ver folio 26

⁴² Ver folio 28 y 29

⁴³ Ver folios 30 a 33

⁴⁴ Ver folio 35 a 38

En este documento, fueron señaladas como causales de la aprehensión las identificadas como 1.6 y 1.19, conforme las menciona el artículo 202 y 502-2 de la norma aduanera.

10. Acta de posesión **No. 010 del 3 de enero de 2012⁴⁵**, mediante la cual se formaliza la vinculación de la servidora XXXXX, quien fuera asignada a la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla en la División de Gestión de la Operación Aduanera.
11. Oficio **No. 100214308-1005 del 27 de junio de 2013⁴⁶**, suscrito por la Jefe de Coordinación de Historias Laborales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, allegando el extracto de la hoja de vida y certificación de vinculación de la servidora XXXXX.
12. Oficio suscrito por XXXXX del 16 de enero de 2014⁴⁷, por medio del cual entrego la sustanciación del expediente **DM 201320130799**, ya que no compartía los argumentos esgrimidos por el Jefe de la División, en consecuencia, lo dejó a disposición de la doctora XXXXX Jefe del GIT Vía Gubernativa.
13. Correo electrónico por medio del cual XXXXX, le expresa al señor XXXXX, no estar de acuerdo con sus argumentos para cambiar el sentido de la revocatoria, en este sentido, le manifiesta el señor **XXXXX** que el mismo será revisado por el Director Seccional de Aduanas, quien tomaría la decisión definitiva.
14. Oficio **No. 1-87-201-401-0323 del 14 de julio de 2017⁴⁸**, firmado por XXXXX, quien como Jefe de Personal (A) informó que, la servidora XXXXX no participó en ninguna capacitación durante el mes de abril del año 2013.
15. Resolución **No. 778 del 17 de junio de 2013⁴⁹**, por medio de la cual se ordenó el decomiso de la mercancía, suscrita por el Jefe GIT de Investigaciones Aduaneras XXXXX.
16. Resolución **No. 1195 del 6 de septiembre de 2013⁵⁰**, a través de esta decisión, se rechazó un recurso de reconsideración, el cual fue impetrado contra la decisión que ordenó el decomiso de la mercancía.
17. Copia del Recibo Oficial de Pago de Tributos Aduaneros y Sanciones Cambiarias **No. 69800354655-1** del 28 de diciembre de 2012⁵¹.
18. Oficio **No. 187000201-500 del 8 de noviembre de 2017⁵²**, suscrito por XXXXX como Director Seccional de Aduanas Barranquilla (a), allegando la solicitud de revocatoria de la Resolución de Decomiso elevada por XXXXX⁵³; *"Auto y Acta de Inspección"* **No. 00191 del 28 de diciembre de 2012⁵⁴** elaborada por la disciplinada, por cuenta del equipaje no acompañado de la señora XXXXX identificada con la cedula de ciudadanía No. XXXXX suscrita por la aquí investigada y el señor XXXXX; factura **No. 71-111296⁵⁵** por valor de USD \$ 16.00, por cuenta del manejo de la guía aérea que ampara la mercancía de la señora XXXXX; copia de la

⁴⁵ Ver folio 40

⁴⁶ Ver folios 48 a 50

⁴⁷ Ver folio 204

⁴⁸ Ver folio 224

⁴⁹ Ver folios 242 a 249

⁵⁰ Ver folios 251 a 254

⁵¹ Ver folio 255

⁵² Ver folio 288 a 323

⁵³ Ver folios 289 a 308

⁵⁴ Ver folio 309

⁵⁵ Ver folio 310

declaración de viajeros No. 5308179547489 del 13 de diciembre de 2012⁵⁶; recibo de pago No. 690800354656 del 28 de diciembre de 2012⁵⁷, a nombre de XXXXX; Resolución No. 243 del 5 de febrero de 2014⁵⁸ por medio de la cual se decide la revocatoria directa presentada por la viajera XXXXX.

19. Proyecto de revocatoria presentado por la servidora XXXXX,⁵⁹ a través del cual se decidía sobre la petición elevada por la usuaria aduanera.

7.2.2. Pruebas testimoniales:

1. Declaración juramentada del señor XXXXX, quien para la fecha de los hechos fungía como Jefe del Grupo Informal Viajeros, diligencia llevada a cabo el 9 de octubre de 2017⁶⁰.

Respecto a la fecha de ingreso y de comunicación de funciones, el declarante no recordó con exactitud el momento de las mismas, sin embargo, destacó que era posible que dentro del Grupo Informal de Viajeros se hallara una copia de esto, además señaló, que podrían inferirse con relación a las evaluaciones de desempeño, puesto que allí se fijan compromisos o roles que fuese a desempeñar cada funcionario.

Importante también resulta ser la afirmación en la que, respecto a la pregunta por parte de la defensa relacionada con la capacitación, adujo: “...Claro que sí, ya que cada uno de los funcionarios que van llegando se les realiza una inducción y creo que, para la fecha indicada, era por el término de una semana, y allí mismo, se le indican las normas que reglamentan el régimen de viajeros e incluso, se le entregan folletos donde se indican cada uno de los procesos que allí se manejan”, en el mismo sentido mencionó: “En el momento no recuerdo el nombre de la funcionaria que se le asignó pero, a todos y cada uno de los funcionarios que van ingresando, por parte del suscrito, se le da instrucciones de acuerdo a la reglamentación del régimen de viajeros y, además, se invitan a las capacitaciones que se imparten a las líneas aéreas y demás autoridades que operan en el Aeropuerto, que están establecidos en el Aeropuerto Ernesto Cortizos de Soledad, Atlántico. Además, podemos agregar, que el Grupo recibía capacitaciones de otros funcionarios de esta misma Dirección en la medida que se solicitaba por parte de la jefatura del grupo, donde participaban todos los funcionarios”. Aunque en la diligencia no recordó el nombre de quienes realizaron esta labor, si precisó que pueden existir planillas respecto a las capacitaciones, puesto que dependía del turno en el cual se encontrara el servidor.

Ahora bien, en correspondencia con los hechos y la presunta falla en el computador, el abogado de la defensa preguntó el uso que se le daba y las condiciones del mismo, situación sobre la que el señor XXXXX señaló que efectivamente existía un computador en el cual se elaboraban las actas y se había diseñado un modelo de las mismas para ser diligenciadas por cada uno de los funcionarios; debían imprimir 3 copias que se entregarían al viajero, al archivo y al depósito; que las condiciones técnicas eran normales y no existían requerimientos sobre ese particular⁶¹, sobre este ítem, también señaló la forma para reportar la falla en un equipo de cómputo.

⁵⁶ Ver folio 311

⁵⁷ Ver folio 312

⁵⁸ Ver folios 313 a 323

⁵⁹ Ver folios 363 a 367

⁶⁰ Ver folios 277 a 285

⁶¹ Ver folio 280

Adicionalmente, el testigo se refirió al tema vinculado con los errores y las causas de los mismos por cuenta de la falla en el sistema, situaciones de las que pudo referirse de la siguiente manera: *“Sí recuerdo, que en la elaboración del Acta de inspección o reconocimiento del equipaje no acompañado realizado por la funcionaria se presentó un inconveniente técnico en el sentido de que una vez terminada el Acta y al imprimirla el mencionado documento, el sistema no le guardo los datos o la información que se estaba haciendo en el sistema operativo que funcionaba para esa diligencia. Es decir, nos dimos cuenta posteriormente que la impresión que salió del sistema fue un Acta que existía de otro equipaje no acompañado y se presentó un inconveniente de inconsistencia en la naturaleza de la mercancía que se había inspeccionado por parte de la funcionaria”,* añadiendo respecto a las fallas o errores que: *“ Sí, es posible que se haya presentado esta inconsistencia por error técnico, ya que el sistema operativo no le guardo la información que la funcionaria estaba alimentando en el sistema, de hecho, cuando imprime insisto en esto, sale un acta que estaba debidamente diligenciada y tramitada de otro equipaje no acompañado, es decir, salió un acta existente en el sistema operativo del Grupo Informal Viajeros, donde inferimos que hubo un error técnico en el acta impresa por la funcionaria”.*

En esta misma diligencia, se refirió al momento en el cual el valor a del equipaje a declarar es 0 o cuando debe existir el pago de un tributo único, a lo que atino al mencionar que los efectos personales tienen un valor 0, pero, los demás debe existir un 15% de impuesto único, que el monto límite es de USD \$2.500. Además describió brevemente el procedimiento para la liquidación del tributo y la forma en la cual se debe hacer el pago, con estos documentos se procede a dar el levante⁶², en lo que respecta a la operación de comercio exterior de la señor XXXXX no tuvo conocimiento que se hubiera efectuado el pago del mencionado gravamen.

Finalmente, hizo referencia a las altas capacidades laborales de la funcionaria XXXXX, de quien afirmó tener altas calificaciones en su desempeño, así como exaltó su compromiso con la entidad.

2. Diligencia de declaración juramentada de la señora XXXXX, quien para la época de los hechos fungía como Analista IV y hacia parte de la División Gestión de la Operación Aduanera GIT Control de Carga y Tránsito-Aeropuerto de carga. Este testimonio se recibió el 4 de diciembre de 2017⁶³.

Inicialmente, la funcionaria manifestó desconocer el procedimiento para dar trámite a la importación bajo la modalidad de equipaje no acompañado, puesto que adujo no ser de su competencia directa. Sin embargo, afirmó que siguiendo las instrucciones del Director Seccional de Aduanas de Barranquilla emitida mediante nota interna, en donde se da el perfilamiento, la mercancía fue objeto de reconocimiento por parte del grupo de Carga y de fiscalización, puesto que era producto de una perfilación realizada por el Director Seccional de Aduanas.

En relación con la nota interna No. 0457 del 29 de abril del 2013, la servidora manifestó que dicho documento llegaba inicialmente al Jefe del Grupo y luego, se asignaba al funcionario del grupo que se encontrara en turno, por lo tanto, por estar ella disponible le fue

⁶² Ver folio 284

⁶³ Ver folios 349 a 353

encargada esa labor. Se debe resaltar que la testigo desconocía el Acta de Inspección y Reconocimiento de equipaje no acompañado No. 00050 del 29 de abril de 2013, en el mismo sentido, desconoció si la mercancía hubiera sido objeto de entrega a la viajera.

3. XXXXX, aludió que, al momento de revisar la mercancía, esta no correspondía a lo descrito en la guía de transporte, puesto que se trataban de elementos que no podían ser parte de un equipaje no acompañado y estos claramente superaban el valor permitido para la franquicia de tributos⁶⁴ y los 3 elementos permitidos. Añadió sobre su labor que, las funciones de quien hace el control previo se relacionan con la descripción de la mercancía, el número de bultos y el peso de la misma.

El procedimiento inicia, conforme a la voluntad de retiro de la mercancía de parte de XXXXX, quien se acercó a las instalaciones de su transportadora **TAMPA CARGO**, quienes tenían el aviso del seguimiento a esta guía y procedieron a llamar al grupo al que pertenecía la testigo, en consecuencia, procedió a dar apertura de las cajas y logra identificar que se trataban de 15 piezas que catalogó como electrodomésticos e informó inmediatamente a su jefe y posterior a eso, se trasladó la mercancía al depósito para el trámite correspondiente.

La servidora, manifestó que debió remitirse a la lista de referencia de precios de la DIAN, ya que, debía asegurarse que la misma cumpliera con los requisitos para ser tramitada como equipaje no acompañado, sin embargo, muchas referencias no aparecían en la lista de precios y debieron ser consultadas por internet, a esto le añade que las cajas estaban separadas y envueltas en papel plástico transparente y en buen estado, adicionalmente advirtió que, por su conocimiento en los tributos que debía declarar este tipo de mercancía, así hubiera existido el pago del tributo único, esta sobrepasaba el cupo que se permite para la modalidad. Sobre este particular, aseguró que el funcionario de reconocimiento no puede omitir la verificación completa de los requisitos de ingreso al país de la mercancía.

En consecuencia, la servidora manifestó ante la pregunta de la defensa sobre los trámites que pudiese adelantar el dueño de la mercancía que: el viajero puede presentarse ante la administración con los documentos soportes para legalizar su mercancía.

4. Declaración juramentada de la señora XXXXX, quien, para la época de los hechos, se encontraba desempeñando funciones como abogada de la vía gubernativa. Testimonio llevado a cabo el día 4 de diciembre de 2017⁶⁵.

La servidora manifestó que, conforme a sus funciones y competencias para la época, fue la encargada de hacer el estudio sobre la procedencia o no de la revocatoria directa, acción impetrada por XXXXX, por cuenta de las presuntas fallas de la administración que no podrían imputársele a ella y con esto, causarle un perjuicio económico. El proyecto de resolución proyectado por la trabajadora contemplaba la devolución de 3 elementos de los importados, previo al pago del tributo único, pero el Director Seccional de la época no acepto dicho borrador y por ello, XXXXX procedió a devolverlo al Jefe de la Vía Gubernativa y se lo informó al Jefe de la División Jurídica, eso sí, aclara que el proyecto de ella no fue finalmente el que decidió sobre la revocatoria. Esto, aun afirmando que desde la entrega del expediente, no tuvo más conocimiento sobre el particular.

En efecto, la funcionaria pudo determinar que la información reportada por la viajera en su escrito de revocatoria, en cuanto a la posible existencia de un error en la información

⁶⁴ Ver folio 351

⁶⁵ Ver folios 355 a 359

reportada en Acta No. 00050, esto por cuenta de la información recopilada dentro del estudio de la acción de control.

Ahora bien, menciona la señora XXXXX, en razón a una pregunta de la defensa sobre la calificación de contrabando o no de la mercancía objeto de debate, que no se podría catalogar de esta forma, por cuenta de la presentación ante la autoridad aduanera, ya que, de tratarse efectivamente de un contrabando, no hubiera proyectado una resolución en los términos que se hizo, añadiendo que fue presentada por contar con un documento de transporte.

En lo relacionado directamente con el trámite de ingreso del equipaje no acompañado, la declarante manifestó desconocerlo, entendiendo que ella no había sido parte del grupo de viajeros, sin embargo, recordó el límite en cuanto a la cantidad de elementos para importar, la existencia de una lista y los documentos que para ella serían necesarios.

Al final de la diligencia, resaltó que pudo percibir alrededor de los hechos, la existencia de un interés personal del Director Seccional de Aduanas de la época.

7.2.3. Inspecciones administrativas

1. Visita especial del 18 de julio de 2013⁶⁶, llevada a cabo en la División de Gestión de Fiscalización, de la cual se pudo obtener copia completa del expediente **DM 2013201300799**, adelantado por cuenta de la mercancía ingresada como equipaje no acompañado por la señora XXXXX, tal como lo demuestra el oficio 1-87-238-415-199 de la fecha antes mencionada. Adicionalmente se obtuvo copia de la declaración de viajero No. 5308179642624 y del Acta No. 00050 del 29 de abril de 2013.
2. Visita especial del 18 de septiembre de 2013⁶⁷, la cual se adelantó en el Grupo de Viajeros ubicado en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz y en donde se pudo obtener nuevamente copia de la declaración de viajeros de XXXXX y del acta No. 00050 del 29 de abril de 2013, con la salvedad de esta última, que tiene la palabra *ANULADO*.
3. Visita especial del 11 de octubre de 2017⁶⁸, nuevamente se revisó el expediente **DM2013201300799**, por cuenta de la existencia de 55 folios adicionales a la primera inspección, en consecuencia, se obtuvieron copias pertinentes y de importancia para la investigación que se adelantaba. Entre ellas, la solicitud de revocatoria de la resolución de decomiso elevada por XXXXX, copia del “*Auto y Acta de Inspección*” No. 00191 del 28 de diciembre de 2012, declaración de viajeros No. 5308179547489, recibo de pago oficial No. 6908003546569 y la resolución 243 del 5 de febrero de 2014 por medio de la cual se resolvió una solicitud de revocatoria directa.

7.2.4. Análisis de las pruebas:

La servidora XXXXX es funcionaria activa de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y se encuentra adscrita a la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla. Para la época de los hechos hacia parte de la División de Gestión de la Operación Aduanera desde el mes de enero del año 2012, información probada por cuenta del acta de posesión de la disciplinada, aportada en legal y debida forma al expediente.

⁶⁶ Ver folio 84

⁶⁷ Ver folios 111 a 112

⁶⁸ Ver folios 271 a 273

Se tiene acreditado al interior de la actuación, que la señora XXXXX, ingresó al país el 21 de marzo de 2013, por lo tanto, mediante declaración de equipaje y título representativo en dinero No. **5308179642624**, informó que no retornaba con la totalidad de su equipaje, como lo indica en la casilla correspondiente y consignó el periodo de tiempo en el cual estuvo fuera del país, del que se pudo identificar se trató de 5 días en Estados Unidos de América.

También está demostrado, que luego de su viaje, el día 29 de abril del año 2013 se dirigió a la DIAN Seccional de Aduanas Barranquilla, con el fin de retirar el resto de su equipaje, el cual había llegado a la ciudad amparado con la guía aérea No. **72989014730** del 27 de abril de 2013, documento de transporte emitido por la empresa **O.K. CARGO, CORP.**, gestionado por **TAMPA CARGO** con destino final la ciudad de Barranquilla.

Importante resaltar que, si bien el equipaje ingresó al país presuntamente con los documentos soporte pertinentes, resultó que el contenido del mismo se encontraba claramente por encima del límite para la franquicia de tributo y para la cantidad de ítems permitidos por esta modalidad de importación, hecho probado con la guía área, lugar donde se observa que en la casilla *No. of pieces RCP*, se consignó el número 15 y el valor total del trámite fue de USD \$3,566.90. Si bien este último no es el valor de referencia para la liquidación de impuestos, si lo son las facturas anexas No. 43001 y 43024, la primera expedida el 5 de diciembre de 2012 por valor de USD \$1,159.00 y la segunda, con fecha de expedición el 13 de diciembre de ese mismo año y por valor de USD \$1,335.00, estos documentos, son necesarios para verificar el cumplimiento de los montos, los cuales sumaban USD \$2,494.00.

Antes del mencionado acto de reconocimiento de la mercancía, a través de la nota interna No. 0457 del 29 de abril de 2013, se perfiló esta mercancía para su inspección, debido a los resultados del análisis y perfilamiento del riesgo, información y resultados del P.C.M., y se trataba del control al manifiesto de carga No. **11657004279548** del 27 de abril de 2013 y arribado en avión a la ciudad de Barranquilla.

En razón a las funciones que tenía la servidora XXXXX, ella procedió a trasladarse a las instalaciones de **TAMPA CARGO**, con el fin de adelantar las diligencias de inspección y reconocimiento de equipaje no acompañado, en consecuencia, procedió a dejar los registros de su actividad en el Acta No. 00050 del 29 de abril del año 2013, presentando incongruencias en los campos asignados a la declaración del viajero, fecha, tasa de cambio, descripción del contenido del equipaje y observaciones. Esto corroborado en los testimonios de los servidores XXXXX, XXXXX y XXXXX, además de ser reconocido por la investigada en su escrito de descargos y por su apoderada en sus alegatos de conclusión.

Consecuencia de la expedición de este documento, la usuaria aduanera XXXXX, se trasladó al depósito donde se encontraba la mercancía de su propiedad, sin embargo, al llegar allá no pudo retirarla, puesto que ésta tenía una revisión pendiente por parte del grupo de Carga y por ello tuvo que esperar a la llegada del funcionario encargado, servidor que comparó lo registrado en el acta y el contenido de las cajas, observando la incongruencia y actuando conforme a la ley cuando se presentan estos casos de acuerdo al relato de la servidora XXXXX.

Producto de la revisión de la totalidad de los elementos que componía el equipaje no acompañado, se elaboró Acta de Diligencia No. 00853 del 28 de abril de 2013, por la configuración de la causal 1.27 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, sin embargo, conforme al Acta de aprehensión No. **87-0049FISCA** del 8 de mayo de ese calendario, se establecieron como causales de la retención de la mercancía, las establecidas en los numerales 1.6 y 1.19 del artículo 502 del Estatuto Aduanero.

La viajera, haciendo uso de sus derechos, propuso objeciones a la aprehensión de la mercancía mediante escrito del 23 de mayo de 2013⁶⁹, sin embargo, en decisión del 17 de junio de ese año, la Dirección Seccional de Aduanas ordenó el decomiso de la mercancía, por encontrarse probadas las causales por las que se produjo la aprehensión de la misma, en tal sentido, aun cuando la señora XXXXX presentó su recurso de reconsideración, este fue rechazado por extemporáneo, dejando en firme la decisión del decomiso a favor de la nación.

Por cuenta de este acto administrativo, la viajera impetró una solicitud de revocatoria directa alegando que la autoridad aduanera desconoció sus derechos, ya que cumplió con todas los requisitos para poder tramitar su equipaje no acompañado, añadiendo que el mismo se encontraba con documento de transporte y demás suficientes para retirar sus bienes del depósito; sin embargo, la funcionaria XXXXX pudo establecer si bien se presentó un error en la administración por cuenta de la retención de su mercancía, la propietaria de la misma debía pagar un tributo único y se le devolverían 3 elementos que no sobrepasaran el tope permitido de USD \$2.500, decisión que ella proyectó y no tuvo la aprobación del Director Seccional, pero se trató de la misma motivación y forma de resolver que se tuvo en cuenta en la Resolución 243 del 5 de febrero de 2014.

Todo esto para destacar que, conforme a la declaración de XXXXX el “Auto y Acta de Inspección” No. 00050 del 28 de abril de 2013 tuvo incongruencias y éstas tuvieron que ver con el uso de un modelo de plantilla anterior, para lo cual se debe tener en cuenta lo consignado en la distinguida con el consecutivo No. 000191 del 28 de diciembre de 2012, firmada por la viajera XXXXX y por la aquí investigada, donde hubo lugar a un pago de impuesto a través del recibo de pago oficial No. 6908003546569; liquidación de USD \$200.00 como valor de los efectos personales, ropa usada y perfumes y una tasa de cambio de \$1.788,87.

Lo expuesto deviene en las presuntas fallas del computador utilizado para diligenciar el formato, hecho que mencionó la disciplinada se produjo por no guardar los cambios efectuados en ese documento, situación que conoció el Jefe del Grupo Viajeros pero no concuerda con los datos que al parecer se dejaron igual, ya que, en varios ítems la información cambio y está presente en el acta entregada a XXXXX, además, no hubo un reporte al área encargada sobre estas fallas.

Finalmente, esto desemboca en la capacitación de XXXXX, de quien la defensa y ella misma refirió no tener la suficiente instrucción para sus labores pero, según la declaración de quien fuera su jefe, ella hizo parte de un plan de entrenamiento, además, tenía altas calificaciones por el documento de inspección a la viajera XXXXX, de esta manera se puede probar que contaba con planitud de conocimiento del procedimiento aduanero.

7.3. DE LA TIPICIDAD DISCIPLINARIA

La tipicidad es una institución disciplinaria que deviene del principio de legalidad constitucional, el cual a su vez encuentra eco en el inciso 2º del artículo 29 de la Carta Política y en los artículos 4º de la Ley 734 de 2002, al concretar el juzgamiento “conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa” o “por comportamientos que estén descritos como falta en la Ley vigente al momento de su realización”⁷⁰.

En relación con este principio, la jurisprudencia constitucional ha precisado que hace parte esencial del principio “*nullum crimen, nulla poena sine lege*”, de manera que se exige que:

⁶⁹ Ver folios 36 a 76 del Cuaderno Anexo No.1

⁷⁰ Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-030 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva

“La abstracta descripción que tipifica el legislador con su correspondiente sanción debe ser de tal claridad que permita a su destinatario conocer exactamente la conducta punitiva; en principio se debe evitar pues la indeterminación para no caer en una decisión subjetiva y arbitraria”. Así mismo, ha expresado que con base a este principio “el legislador no solo está obligado a describir las conductas que califica como hechos punibles o infracciones disciplinarias, sino además a hacerlo de forma completa, clara e inequívoca, de manera que permita a sus destinatarios tener certidumbre o certeza sobre los comportamientos ilícitos, es decir, de saber con exactitud hasta donde llega la protección jurídica de sus propios actos o actuaciones.”⁷¹

Bajo ese entendido, probada objetivamente la ocurrencia de la conducta relacionada con la expedición irregular del “Auto y Acta de Inspección” No. 00050 del 28 de abril de 2013, resulta ahora procedente determinar, si los comportamientos reprochados constituyen falta disciplinaria, al tenor de lo expuesto por nuestra Honorable Corte Constitucional, así:

El principio de tipicidad se compone de dos aspectos, (i) que “exista una ley previa que determine la conducta objeto de sanción” y (ii) “la precisión que se emplee en ésta para determinar la conducta o hecho objeto de reproche y la sanción que ha de imponerse”⁷², este último aspecto se encuentra orientado a reducir al máximo la facultad discrecional de la administración en el ejercicio del poder sancionatorio que le es propio.

En consecuencia, el auto a través del cual se elevaron cargos en contra de la señora XXXXX, describe las conductas y la imputación fáctico-objetiva, de la siguiente manera:

Se le atribuyó la conducta descrita en el artículo 48 numeral 44 de la Ley 734 de 2002, materializada al favorecer en forma deliberada el ingreso de bienes al territorio nacional sin el lleno de los requisitos exigidos por la legislación aduanera y la descrita en el numeral 1 de ese mismo artículo, que nos remite al Código Penal, en lo concerniente a la adecuación de los hechos al tipo penal de falsedad ideológica en documento público⁷³, pues con ocasión a sus funciones en la División de la Operación Aduanera en el Grupo Informal de Viajeros, ubicado en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz de la ciudad de Barranquilla, el día 28 de abril de 2013, autorizó el trámite de ingreso de una cocina, compuesta por 15 piezas y para ello, se valió de un procedimiento de revisión que adelantó y no consignó en su totalidad en el acto administrativo.

Respecto al **primer cargo**, entendiendo las anteriores precisiones, encuentra este Despacho que la funcionaria XXXXX, conjugó el verbo rector que prescribe la norma disciplinaria, al “favorecer” en forma deliberada el ingreso de mercancía sin el lleno de los requisitos exigidos por la legislación aduanera, pues con su comportamiento, autorizó a través del “Auto y Acta de Inspección” de equipaje no acompañado No. 00050 del 28 de abril de 2013, que la señora XXXXX retirara la mercancía de su propiedad sin el cabal cumplimiento de las exigencias de la norma aduanera, tal como se establece a continuación:

En primer lugar, ha de indicarse que la señora XXXXX en su calidad de servidora adscrita al Grupo Informal de Viajeros de la Dirección Seccional de Aduanas tenía a su cargo, entre otras funciones, realizar labores de inspección y reconocimiento de mercancía, por lo cual resulta válido afirmar que la funcionaria tenía pleno conocimiento de las normas aduaneras aplicables para la importación de

⁷¹ Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-796 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil

⁷² Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-564 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

⁷³ Ley 599 del año 2000, Título IX Delitos contra la fe pública, Capítulo 3, De la falsedad en documentos, Artículo 286: Falsedad ideológica en documento público. El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años

mercancía a través del equipaje no acompañado, y en ese sentido tenía la facultad para exigir o controlar el cumplimiento de la legislación aduanera.

Consecuentemente y de acuerdo con la modalidad de importación, el estatuto aduanero faculta a los usuarios hacer una importación de manera directa, para el caso concreto, se trató del equipaje del viajero, que en caso de no superar los USD \$1.500,00, no sería objeto de cobro de tributos, esto amparado en el artículo 207 del Decreto 2685 de 1999, situación que para el equipaje no acompañado de la señora XXXXX no se cumplió, puesto que las dos facturas que amparaban su mercancía, sumaban un valor total de USD \$ 2.494,00, por lo tanto, debían ser objeto de cobro del tributo único del 15% ad valorem, sin embargo y como la mercancía se registró como efectos personales, esto conlleva a liquidar en cero (0) el valor a pagar.

Para mayor claridad se traen a colación las normas aduaneras infringidas:

<<ARTICULO 207. EQUIPAJE CON FRANQUICIA DEL TRIBUTO ÚNICO. Los viajeros que ingresen al país tendrán derecho a traer equipaje acompañado, sin registro o licencia de importación, hasta por un valor total de mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$1.500) o su equivalente y con franquicia del tributo único.

Los efectos personales que ingrese el viajero no se tendrán en cuenta para la determinación del cupo de mercancías de que trata este artículo (...)>>

<<ARTICULO 208. EQUIPAJE CON PAGO DE TRIBUTO ÚNICO. Los viajeros que ingresen al país y acrediten una permanencia mínima en el exterior de cinco (5) días calendario, tendrán derecho a traer como equipaje acompañado o no acompañado, sin registro o licencia de importación y con el pago del tributo único de que trata el artículo 209 del presente Decreto, hasta tres (3) unidades de cada uno de los siguientes bienes: artículos de uso doméstico sean o no eléctricos, artículos deportivos y artículos propios del arte u oficio del viajero, hasta por un valor total de dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 2.500) o su equivalente(...)>>

Las definiciones transcritas, prueban que, al momento de realizar la liquidación de impuestos por parte de la investigada, pasó por alto el valor de toda la mercancía y ello, conllevó a la omisión en el cobro del impuesto correspondiente; esta labor, de verificar el precio y con base en este, realizar una liquidación para el pago de tributos, era conocida y aplicada por la funcionaria XXXXX, prueba de ello, existe el ““Auto y Acta de Inspección”” No. 000191 del 28 de diciembre de 2012, documento elaborado por la disciplinada y que cuenta con esta actividad de control aduanero.

En lo concerniente a la cantidad de elementos autorizados para ingresar a través de esta modalidad, se tiene claro que, el artículo 208 del Estatuto Aduanero, expresamente señala: **“(...) hasta tres (3) unidades de cada uno de los siguientes bienes: artículos de uso doméstico sean o no eléctricos, artículos deportivos y artículos propios del arte u oficio del viajero, hasta por un valor total de dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 2.500) o su equivalente (...))”**, por consiguiente, no se trataría de un simple descuido al momento de hacer una inspección, más bien se trata de una acción deliberada para desconocer la existencia de 15 piezas de mercancía, lo que conllevaría a que esta importación no cumpliera con los requisitos exigidos en esta modalidad y resultará en un cambio de la misma, además de la aprehensión de la totalidad de ella. Esto, aun contando con el pago de tributo único de los objetos que no superaran la suma de dinero mencionada.

A pesar del incumplimiento de los requisitos para la modalidad de importación a través de equipaje no acompañado, la funcionaria otorgó el levante **MANUAL** No. 872013M7200000001 sin que tuviera en cuenta lo establecido en los numeral 3 del artículo 128 del Decreto 2685 de 1999, que establece:

<<ARTICULO 128. AUTORIZACIÓN DE LEVANTE⁷⁴. La autorización de levante procede cuando ocurra uno de los siguientes eventos: (...)

4. Cuando practicada la inspección aduanera física, se establezca la conformidad entre lo declarado, la información contenida en los documentos soporte y lo inspeccionado (...)>>

Por consiguiente, no solo hubo un incumplimiento de la legislación aduanera en cuanto al trámite del equipaje no acompañado, sino también en lo concerniente al levante otorgado, puesto que, de haber existido una revisión formal a los documentos soporte de la importación, no hubiere autorizado el ingreso a territorio nacional de la mercancía contenida en la lista de empaque **WR#0020057472**⁷⁵, ya que se hace evidente un incumplimiento de las obligaciones mínimas para esta importación por cuenta de la modalidad de importación.

En consecuencia, tenemos que la señora XXXXX, no dio aplicación a los artículos 128 y 208 del estatuto aduanero, situación que se tradujo en la autorización de ingreso al país de la mercancía compuesta por 15 piezas sin el pago de tributo único y excediendo la cantidad permitida, en consecuencia, al tratarse de requisitos *sine qua non* para llevar a cabo una importación de esta naturaleza, se favoreció el ingreso de mercancía sin el lleno de los requisitos exigidos en la legislación aduanera⁷⁶.

Con la anterior acción la funcionaria XXXXX, también dio lugar a la falta que se adecua desde la perspectiva objetiva a la descripción típica del Código Penal consagrada en el artículo 286 del Código Penal que establece: <<Falsedad ideológica en documento público. **El servidor público que, en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad**, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años>> (negrillas y subrayado propios), de esta forma, se encuentra dentro del ámbito de tipos en blanco o números abiertos, regulado por el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

Como puede advertirse, entonces, debemos realizar una valoración en conjunto, objetiva y crítica de las pruebas practicadas con el fin de determinar si, en principio, se cumplen los requisitos del tipo objetivo.

Para el estudio de esta categoría dogmática (tipicidad) y particularmente el tipo objetivo, inicialmente debemos destacar se trata de un delito especial que exige un sujeto activo calificado, pues esta conducta solo puede ser cometida por un servidor público. En el caso particular, se cumple con la calificación especial del sujeto activo, pues con las pruebas recaudadas se demuestra que la aquí investigada, para la época de los hechos (año 2013), fungía como funcionaria de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla.

A la anterior conclusión arribamos por cuenta del Oficio **No. 100214308-1005 del 27 de junio de 2013**⁷⁷, suscrito por la Jefe de Coordinación de Historias Laborales de la Dirección de Impuestos y

⁷⁴ Se entiende por Levante de mercancías, como el acto por el cual la autoridad aduanera **permite a los interesados la disposición de las mercancías previo cumplimiento de los requisitos legales** o de la constitución de garantía, según corresponda.

⁷⁵ Documento mencionado en la casilla *handing information* de la guía aérea No. 729-9014730

⁷⁶ Congreso de la República, Ley 734 de 2002 Por medio del cual se expide el Código Disciplinario Único, Artículo 48, Numeral 44°: Favorecer en forma deliberada el ingreso o salida de bienes del territorio nacional sin el lleno de los requisitos exigidos por la legislación aduanera.

⁷⁷ Ver folios 48 a 50

Aduanas Nacionales, allegando el extracto de la hoja de vida y certificación de vinculación de la servidora XXXXX, documento por el cual podemos inferir que la funcionaria ingresó a la entidad el día 11 de marzo de 2008 a la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla y a partir del 2 de enero del año 2012, fungió como Facilitadora IV dentro de la División de Gestión de la Operación Aduanera de la referida seccional.

Determinado se cumple con la calificación especial del sujeto activo, debe analizarse el verbo rector como elemento del tipo objetivo. Sobre este punto, se encuentra demostrado hasta el momento que la investigada XXXXX conjugó el verbo “consignar” una falsedad, cuando en el “Auto y Acta de Inspección” No. 00191 del 28 de diciembre de 2012, aun desplazándose hasta las instalaciones de la bodega de carga del aeropuerto Ernesto Cortissoz, consignó que la mercancía allí contenida en cajas rotuladas correspondía a “Efectos personales, perfumes, ropa usado (sic)”, cuando en realidad correspondía a un BBQ 54”, Nevera 36”, Freezer 36”, Moldura Neveras, Horno 30”, Microondas, Moldura Microondas, Fabricador de hielo, Frente fabricante, Estufa 36”, Campana 36” Isla, Motor Campana, Ducto Campana, Gaveta Térmica 30” y lavavajillas; es decir, 15 elementos que componen una cocina.

En lo que atañe al bien jurídico, está claro que es la Fe Pública Documentaria que resultó lesionada con la elaboración y suscripción de tal documento autentico, pero que contienen declaraciones contrarias a la verdad. Respecto del sujeto pasivo, también se entiende que es el Estado como Guardián de la Fe Pública.

Sobre el objeto material del ilícito, esto es, el “Auto y Acta de Inspección” No. 00191 del 28 de diciembre de 2012, se encuentra demostrado que el mencionado documento contiene información ilegítima, toda vez que se pudo establecer conforme al Acta de Hechos No. 00853 del 28 de abril de 2013⁷⁸, los testimonios de los funcionarios XXXXX y XXXXX, (quienes realizaron la aprehensión de la mercancía) que la mercancía descrita en el formato aludido, no correspondía a la realidad.

Además, se tiene que las facturas No. 43001⁷⁹ y 43024⁸⁰ describían la totalidad de la mercancía y que, estos títulos valores sumaban USD \$2.494,00, cantidad de dinero que no fue incluida en el espacio No. 20 (Valor) del “Auto y Acta de Inspección” No. 00191 del 28 de diciembre de 2012, ni tampoco correspondía lo contenido en la casilla No. 39 que hizo alusión a los “efectos personales, perfumes, ropa usado(sic)”, sin embargo, si llenó en debida forma los espacios correspondientes a documento de transporte, registro, fecha, peso, levante y fecha del mismo, mencionando que los datos generales como nombre de viajero y funcionario si estaban en regla.

También se debe tener en cuenta que i) con el Acta No. **87-00494FISCA**⁸¹ se describieron los bienes que arribaron al país para su ingreso, ii) fotografías de los elementos que componen la cocina⁸², iii) guía aérea No. **729-89014730**⁸³, describiendo 15 piezas pesando 1346 kilogramos; documentos que acreditan la existencia de un tipo de mercancía que no podía tramitarse del todo bajo esta modalidad, por cuenta de los elevados excedentes en cuanto a los límites de esta forma de importación.

Concordante a lo anterior, se debe mencionar la existencia de un formato anterior de fecha 28 de diciembre de 2012, el cual fue diligenciado en debida forma por XXXXX y del cual el “Auto y Acta

⁷⁸ Ver folio 33

⁷⁹ Ver folio 17

⁸⁰ Ver folio 18

⁸¹ Ver folio 36

⁸² Ver folios 19 y 20

⁸³ Ver folios 12

de Inspección” No. 00191 del 28 de diciembre de 2012, conserva la información en los espacios reservados para la *Descripción del contenido del equipaje/ observaciones (19), fecha (declaración de viajero), recibo oficial de pago y su fecha (32)*, pero aun con esta información, no incluyó la correspondiente a los fletes, seguro, valor base tributos, valor tributo y total, casillas que debieron contener la información acorde a la importación de la señora XXXXX, ya que, como se observa, el formato de control de equipaje si fue modificado por la disciplinada, entendiendo que fue suya la observación de la casilla 39 que relaciona *“efectos personales, perfumes, ropa usado(sic)”* y por ello, el levante es una consecuencia de los datos espurios consignados en dicho *“Auto y Acta de Inspección”*.

Ahora bien, en lo que respecta a los elementos normativos de *“en ejercicio de sus funciones”, “documento público”⁸⁴ y “que pueda servir de prueba”*, se constata que fue elaborado y firmado por la disciplinada en ejercicio de sus funciones, y que con ello se pretendió autorizar el ingreso de 15 elementos que constituían una cocina. Finalmente, la exigencia descriptiva de la infracción disciplinaria relativa a la conducta asumida por la disciplinada, también se describe a título de dolo, porque ella sabía que estaba consignando una falsedad durante la elaboración del documento y libremente asumió esa circunstancia al implantar su firma, lo cual refleja los elementos cognoscitivos y volitivos de la modalidad.

En virtud de lo expuesto, se insiste que la funcionaria XXXXX, incurrió en la conducta descrita como falta gravísima del artículo 48 numeral 1° de la Ley 734 de 2002, con remisión al artículo 286 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), al consignar una información falsa en el *“Auto y Acta de Inspección”* No. 00191 del 28 de diciembre de 2012.

Por otro lado, el objeto jurídico se vio lesionado, tal y como se analizará al momento de valorar la antijuricidad material. De igual manera, se debe tener en cuenta que la falta se cometió por omisión, por ende, se debe tener en cuenta lo regulado por el artículo 27 de la Ley 734 de 2002 que dispone:

<<Artículo 27. Acción y Omisión. Las faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones. Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo>>

7.4. DE LA ILICITUD SUSTANCIAL

Verificada la existencia de la conducta realizada por la señora XXXXX y su tipicidad, se hace necesario examinar la ilicitud sustancial de la misma. Este requisito hace alusión a *“la afectación sustancial de los deberes funcionales, siempre que ello implique el desconocimiento de los principios que rigen la función pública”⁸⁵*

Es importante destacar que los servidores públicos tienen una relación especial de sujeción frente al Estado, la cual demanda mayores exigencias respecto de los particulares y les conmina a tener mayor cuidado en el desempeño de sus tareas y funciones, pues, cada una de ellas, tiene el carácter de públicas y buscan la proyección, satisfacción o ejercicio de derechos ciudadanos, así

⁸⁴ Presidencia de la República, Decreto Ley 1400 de 1970 Por medio del cual se expide el Código de Procedimiento Civil, Capítulo VIII Artículo 251 Inciso 3: Documento público es el otorgado por funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es otorgado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública

⁸⁵ ORDOÑEZ MALDONADO, A. (2009). Justicia Disciplinaria: De la ilicitud sustancial a lo sustancial de la ilicitud. Bogotá, Colombia: IEMP Ediciones.

como el desempeño de las tareas de la administración, las cuales tienen la finalidad de proteger intereses públicos.

En ese orden de ideas, la ilicitud sustancial se construye a partir de la violación de los principios de la función pública, es decir, a partir de normas rectoras de su ejercicio, tal como lo señalan los artículos 5° y 22° de la Ley 734 de 2002, así:

<<Artículo 5. Ilícitud sustancial. La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna (...)>>

<< Artículo 22. Garantía de la función pública. El sujeto disciplinario, para salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar el desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes respetará las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes>>

Para tal fin, debe tenerse en cuenta que el bien jurídico tutelado en el derecho disciplinario es la función pública, su buena marcha y el cumplimiento de los principios señalados en el artículo 22 de la citada norma, del que se puede extraer que es deber de todo servidor público sujetar su función a asegurar la prevalencia del interés general, a la defensa del ordenamiento jurídico, a realizar solamente aquello que les está permitido, de donde surge su responsabilidad con ocasión de la vulneración de los principios de legalidad, transparencia, honradez y lealtad, o por abusar de sus derechos, o por incumplir sus deberes y prohibiciones, o por incurrir en las causales de inhabilidad, incompatibilidad y conflicto de intereses, o por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, los servidores públicos se comprometen a cumplir con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, lo que significa que la realización de comportamientos expresamente prohibidos o calificados como atentatorios del ordenamiento Jurídico, sin justificación alguna, pueden resultar violatorios de su deber funcional expresamente definido.

En tal sentido, es evidente que tales principios fueron transgredidos por la funcionaria disciplinaria, ya que, adelantó un trámite aduanero, en el cual se apartó de la normatividad aduanera exigible, y de esta manera desconoció los principios de la función administrativa, sumado a ello, se tiene que a sabiendas de que como servidora pública le es propia la función certificadora de los hechos que le correspondan al ejercicio de su labor, era imperativo que se ciñera a la verdad consignando datos verídicos en el “Auto y Acta de Inspección” No. 00050 del 28 de abril del 2013, por tanto al actuar de manera diversa registrando afirmaciones contrarias a la verdad, autorizó el ingreso de la mercancía al territorio aduanero nacional sin el cumplimiento de los requisitos, comportamientos con los que se configuró el elemento de ilicitud sustancial o antijuridicidad que demanda la estructuración de la falta disciplinaria.

Actuar con el que se puso en tela de juicio la transparencia, objetividad, legalidad, eficacia y eficiencia que debe gobernar el ejercicio de su función, generando sensación de desconfianza, deslealtad, improbidad y ausencia de transparencia dentro de los coasociados, lo cual requiere la respuesta represiva del Estado.

Además, desde el momento en que la disciplinada tomó posesión del cargo⁸⁶, se comprometió a cumplir con la constitución y la Ley, prometiendo atender fiel y lealmente los deberes propios del cargo, de acuerdo a lo ordenado por el artículo 122 de la Constitución Política. Por consiguiente, debió tener presente aquellos comportamientos que le están siendo vedados por estar

⁸⁶ Ver folio 40

expresamente prohibidos o por configurar conductas típicas que puedan representar la realización de delitos.

Con lo anterior, el Despacho encuentra abastecido el presupuesto de antijuridicidad de la conducta, por falta al deber funcional sin justificación alguna conocida.

7.5. DE LA CULPABILIDAD

En lo que respecta a la forma de culpabilidad, el artículo 13 de la Ley 734 de 2002 consagra que “*en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Las faltas solo son sancionables a título de dolo o culpa*”; en este sentido, para el Derecho Disciplinario, el dolo se considera como la intención deliberada que tiene el funcionario investigado de desatender el ordenamiento o el ánimo que lo embarga de quebrantar la norma, de causar daño, o de actuar de manera contraria al interés general o al buen servicio público, del cual tiene conocimiento dada su formación, experiencia, las particulares funciones que le han sido asignadas o por haber sido advertido de la incorrección de su proceder o de la falta de cumplimiento de condiciones fijadas en la Ley, las que debía tener en cuenta y aplicar específicamente⁸⁷.

Conviene entonces mencionar que, en ese sentido, el pliego de cargos fijó el grado de culpabilidad en dolo, pues en ese entonces se consideró que la comisión de la infracción disciplinaria debía enrostrarse a título de dolo, bajo el entendido que la disciplinada conocía la irregularidad desarrollada y aun así se determinó consiente y libremente su desarrollo.

Este Despacho considera que esta situación se mantiene en el mismo sentido en este fallo de primera instancia, atendiendo la forma en la cual exteriorizó el comportamiento. Sobre el dolo, se debe señalar que es la dirección consciente de la voluntad a obtener un resultado típico y antijurídico. Así las cosas, el dolo se estructura en dos elementos, los cuales son el cognitivo y el volitivo, acreditados en el presente acontecer fáctico.

Respecto al elemento cognitivo, tenemos demostrado que la funcionaria XXXXX, para la época de la conducta, laboraba en la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla en la División de Gestión de la Operación Aduanera y en el Grupo Informal de Viajeros, lo anterior implica que la disciplinada conocía los tipos del elemento objetivo, puesto que el haberse desempeñado por más de un año en esa oficina, le permitían conocer y comprender las normas aduaneras que regulaban el procedimiento para inspeccionar el equipaje no acompañado, por lo tanto, al pasar por alto los requisitos establecidos en la ley para este tipo de operaciones, configuró la expresión de favorecer en forma deliberada, sumado a lo anterior, era de su conocimiento que no podía registrar datos falsos en el formato para tal fin, máxime cuando se encuentra probado que ya había realizado este procedimiento 4 meses antes. Esto indica también, que conocía la obligación del pago de tributos en estas operaciones de comercio exterior, hecho probado conforme a la actividad de la funcionaria, sus descargos y el Acta No. 000191 del 28 de diciembre de 2012.

Ahora bien, respecto al elemento volitivo existen unas apreciaciones que se deben tener en cuenta, puesto que la investigada y su apoderada, refieren a la existencia de un error involuntario al momento de diligenciar el formato conocido como “*Auto y Acta de Inspección*” para equipajes no acompañados, esto por cuenta de la edición no guardada del documento, ya que, al parecer y según aseveraron se habría tratado de una falla en el equipo de cómputo que impidió el registro del contenido real del equipaje manteniendo los datos de la plantilla utilizada anteriormente.

⁸⁷ BRITO RUÍZ, F. (2013 4ta edición). Régimen disciplinario: Procedimiento ordinario, procedimiento verbal, pruebas. Bogotá, Colombia: Editorial Legis. Pág.: 184

Sin embargo, estas explicaciones no son acogidas por esta oficina de investigaciones conforme se pasa a exponer:

La plantilla utilizada el día 28 de abril de 2013 y la utilizada en la operación de comercio exterior del 28 de diciembre de 2012, guardan similitud **ÚNICAMENTE** en las casillas relacionadas con los datos de quien elaboró en las casillas No. 19, 23, 32, en lo correspondiente a la fecha de la declaración de viajero y recibo de pago, sin embargo, la información consignada en cuanto al valor y demás elementos ya señalados presentan diferencias sustanciales.

El modelo utilizado el 28 de diciembre de 2012 se trató de la distinguida con el consecutivo No. 000191, fue elaborada por la servidora vinculada a la presente causa, por tanto, ella sabía y era capaz de identificar los errores del documento firmado el 28 de abril del año 2013, máxime si se tiene en cuenta que fue una diligencia que ella realizó y que como se ha expuesto por la experiencia que tenía en el área a la que estaba vinculada, conocía los requisitos para legalizar la importación a través de esta modalidad.

Es por lo anterior, que este Despacho en base a las reglas de la experiencia y la sana crítica, se permite concluir que no resulta creíble que las funciones ejercidas por XXXXX en el mes de diciembre del año 2012, fueran omitidas 4 meses después; y que sugiera como justificación a su actuar la falta de capacitación y la falla en un equipo de cómputo, que bien conocía por sus labores cotidianas, pues contrario a lo alegado la disciplinada contaba con la experticia esperada de una servidora que no tendría reporte de errores de esta índole, puesto que a pesar de no ser una labor diaria (el reconocimiento de equipaje no acompañado), debido a la capacidad de albergar vuelos internacionales del Aeropuerto Ernesto Cortissoz, no era extraordinario que le fueran asignadas las labores propias de revisión e inspección de equipaje no acompañado, a cargo del Grupo de trabajo al cual pertenecía.

Por estas razones, se tiene que la disciplinada pese a conocer plenamente sus funciones y sus deberes como servidora pública, de manera poco eficiente omitió el registro de información veraz en el formato de *"Auto y Acta de Inspección"* de equipaje no acompañado No. 00050 del 28 de abril de 2013, por medio del cual validó el ingreso de una cocina de la señora XXXXX, además, se abstuvo de liquidar el impuesto sobre el valor total de la mercancía que sobrepasaba los límites permitidos para esa modalidad, se menciona que la disciplinada en su escrito de descargos, mantiene su postura respecto a este ítem, por lo tanto, es consciente de su actitud y fue de manera voluntaria que ejecutó dichas omisiones de información, conllevando a que fuera falsa la allí consignada.

En consecuencia, estima este Despacho que está plenamente demostrado que la conducta reprochada a la señora XXXXX fue cometida a título de **DOLO**, pues la disciplinada conocía los hechos de la infracción y quiso su realización.

Ahora bien, el dolo que exige este comportamiento, se debe entender como el conocimiento que tiene el agente, de que la conducta que asume produce consecuencias antijurídicas en tanto es quebrantadora de normas, y pese a contar con tal conocimiento, dirige su voluntad a la comisión de la misma; pues sabido es que el dolo se manifiesta en el conocimiento que se tiene de la falta disciplinaria y en la motivación de que se quiere su realización o se acepta con anterioridad.

Es claro entonces, que la investigada conocía por su experiencia y práctica diaria, que no dar cumplimiento a la norma aduanera de importación bajo la modalidad de equipaje no acompañado, era contrario a la ley, por cuanto, se asocia el autorizar este ingreso con el ilícito conocido como contrabando, esto, por cuenta de reconocer en su escrito de descargos, la existencia de requisitos

legales para esto. En consecuencia, puede afirmar este Despacho que la servidora XXXXX conocía los hechos y de la ilicitud que sobreviene en el incumplimiento de estos requisitos en la legislación aduanera y al incluir información falsa en el “Auto y Acta de Inspección” No. 00191 del 28 de diciembre de 2012.

Por lo tanto, solamente faltaría corroborar la existencia de voluntad en la comisión de la conducta, de la cual, se anticipa que el “Auto y Acta de Inspección” No. 00191 del 28 de diciembre de 2012, que para la servidora no guardó los cambios realizados, sin embargo, existen modificaciones respecto a la misma que corresponden a los datos incluidos por la investigada, tanto así, que ella mantiene su posición en omitir la liquidación de los impuestos, de tal forma que, devino en el registro de información falsa o no correspondiente a la realidad.

7.6. DE LA CONTESTACIÓN A LOS ARGUMENTOS DEL INVESTIGADO

7.6.1. De los descargos presentados por XXXXX:

La servidora, abordó varios aspectos; el primero, respecto al cargo endilgado como favorecimiento deliberado a ingresar mercancía sin el lleno de los requisitos exigidos por la legislación aduanera, expuso que esta falta no se materializó por cuenta de no existir en ningún momento un desborde de sus funciones o atribuciones, para favorecer a un tercero; que la mercancía ingresó al territorio nacional cumpliendo los requisitos exigibles; que la viajera XXXXX si podía ingresar la totalidad de la mercancía por cumplir lo establecido para la modalidad de equipaje no acompañado, afirmando que esa era la modalidad procedente y que no era obligatorio el pago del tributo único; que sumado a ellos se presentó una falla en el equipo de cómputo utilizado para elaborar el acta y que su falta de inducción contribuyó a la comisión de los hechos cuestionados, aspectos que se procederán a responder de manera individual.

Inicialmente, en lo que respecta al abuso de sus funciones, se debe entender que se trata de una expresión para señalar que, las acciones realizadas por la disciplinada, no estuvieron acordes a las acciones que por la Constitución y la Ley, son encomendadas a todo servidor público, entendiendo que, a los servidores públicos se les exige un comportamiento probo en desarrollo de las mismas, en esto, que un actuar bajo la penumbra de las normas, atenta contra los principios que rigen la función pública.

En consecuencia, el actuar irregular de la servidora XXXXX, contravino los principios del servicio público, de tal forma que, con razón al cargo que fungía, fue parcial en su actuar, no fue diligente y con ello, terminó favoreciendo a la señora XXXXX, para ingresar mercancía a territorio nacional sin el lleno de requisitos y, para lograrlo, se valió de su función como inspectora para incluir información falsa en un documento que le correspondió diligenciar.

En lo que respecta a los requisitos exigibles por la legislación aduanera, para el ingreso de mercancía a través del equipaje no acompañado, se deben traer a colación las normas para tal fin, por ello, es importante destacar que, esta modalidad se encuentra mencionada en la Sección X del Decreto 2685 del año 1999.

Para empezar, la modalidad está definida en el artículo 205 así:

<<ARTICULO 205. VIAJEROS. *La modalidad de importación de viajeros sólo es aplicable a las mercancías que no constituyan expedición comercial y sean introducidas por los viajeros, en los términos previstos en el presente Decreto.*

Para tales efectos, no se consideran expediciones comerciales aquellas mercancías que se introduzcan de manera ocasional y consistan exclusivamente en bienes reservados al uso personal o familiar, o bienes que estén destinados a ser ofrecidos como regalo, sin que por su naturaleza o su cantidad reflejen intención alguna de carácter comercial>>

Como se puede observar, efectivamente la viajera XXXXX, podía ingresar su mercancía, ya que, se trataría de una mercancía que sería de uso personal, tal como ella lo aludió en sus escritos de objeción de aprehensión y de revocatoria directa; razón entonces, para traer a colación el siguiente paso en este procedimiento de importación, actividad mencionada en el 3er inciso del artículo 206 ibidem que menciona:

<<ARTICULO 206. PRESENTACIÓN DEL EQUIPAJE A LA AUTORIDAD ADUANERA. *Todo viajero que ingrese a territorio aduanero nacional, estará en la obligación de presentar su equipaje a la autoridad aduanera, para lo cual, se debe diligenciar y presentar una declaración de equipaje por viajero o por unidad familiar, en el formulario que prescriba la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. (...)*

Así mismo, cuando corresponda, se debe someter a revisión de los funcionarios competentes de dicha entidad, los elementos que componen el equipaje, con el objeto de determinar el cumplimiento de las formalidades aduaneras y el pago de los derechos cuando haya lugar a ello.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el formato “Auto y Acta de Inspección” para Equipajes no acompañados, todas las solicitudes de entrega de equipajes de esta clase, se les debe realizar una inspección física por parte del inspector asignado, lo anterior, sin perjuicio de las verificaciones previstas en el estatuto aduanero en el inciso segundo del artículo 130 que menciona, que, el deposito sólo podrá entregar la mercancía respecto de la cual se hubiere autorizado su levante, previa verificación del pago de los tributos aduaneros correspondientes, este ítem, se valorará más adelante.

Ahora bien, continuando con las diligencias gestionadas por XXXXX con la viajera XXXXX, una vez presentados los documentos y realizada la inspección por parte de la servidora, se procedió a la elaboración del “Auto y Acta de Inspección” No. 000150 del 28 de abril de 2013, en la cual se consignó una franquicia de tributo, que fue defendida por la investigada en su escrito de descargos, pero, se debe mencionar que, es el artículo 207 de la norma aduanera que regula esto, mencionando que “los viajeros que ingresen al país, tendrán derecho a traer equipaje no acompañado, sin registro o licencia de importación, hasta por un valor total de mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD\$1.500) o su equivalente y con franquicia de tributo único” y en su segundo inciso menciona que los efectos personales no se tendrán en cuenta para la determinación del cupo de mercancías mencionadas.

Consecuencia de lo expuesto, observando que la funcionaria deliberadamente dejó la información de efectos personales en la casilla No. 19 y consignó en la casilla 39 lo mismo, trató de eludir a favor de la viajera el pago del impuesto, ya que, el equipaje en facturas sumaba USD\$2.494,00, por ende, no le correspondía ser beneficiaria de la franquicia que trata el artículo anterior.

Es por este motivo, que no se puede acoger las justificaciones de la investigada a través de las cuales trató de validar su actuación, en cuanto a la omisión de liquidar el impuesto correspondiente, de tal razón que, de acuerdo con el artículo 208 de la norma antes referida, este equipaje era objeto del pago de tributo único, ya que, el valor total de dicha mercancía sobrepasaba lo estipulado para no acudir al pago del gravamen, en ese sentido, el requisito para retirar la mercancía, en ningún momento se cumplió.

Por lo señalado, se puede identificar que efectivamente se omitieron requisitos exigibles para esta modalidad de importación, puesto que además de la omisión del pago del tributo único, aplicable por el valor de la mercancía, también se presentó una aprobación de ingreso a 15 piezas que componen la cocina, cantidad registrada en la guía de transporte **No. 72989014730**⁸⁸, en la lista de empaque **WR#0020057472**⁸⁹ y en las facturas comerciales. En consecuencia, no se trató de una somera equivocación como pretende hacerlo ver la defensa, sino más bien, un incumplimiento sistemático de los requerimientos para el ingreso de equipaje no acompañado.

Otro tópico mencionado por la investigada era la facultad que tenía la viajera XXXXX para ingresar la totalidad de la mercancía y que esta, cumplía lo establecido para la modalidad de equipaje no acompañado. En lo que corresponde a este particular, se debe tener en cuenta la **Resolución No. 243 del 5 de febrero de 2014**⁹⁰, que revocó parcialmente el acto administrativo **No. 778 del 17 de junio de 2013**⁹¹, por medio del cual se ordenaba el decomiso de la mercancía amparada con la guía aérea **No. 72989014730**, a nombre de la usuaria aduanera mencionada, adicionalmente, se hará mención del borrador presentado por la servidora XXXXX y que no fue aprobado.

La actuación administrativa del 5 de febrero del 2014, tiene un antecedente y este se trata del borrador presentado por la servidora XXXXX, quien devolvió el expediente por no haberse acogido su tesis, la cual, ordenaba la revocatoria total del auto que resolvió decomisar la totalidad de la mercancía de la señora XXXXX, esta decisión, tuvo como fundamento el presunto error de la administración al momento de diligenciar el “*Auto y Acta de Inspección*” **No. 00050 del 28 de abril de 2013**, en consecuencia, para la sustanciadora era suficiente motivación para tomar esta determinación⁹².

Ahora bien, dentro de la parte resolutive de ese borrador, se ordenaba solamente la devolución de 3 ítems a la viajera, previo el pago del **TRIBUTO ÚNICO**, la cantidad mencionada, corresponde al límite en esa modalidad; sobre los 12 restantes, conminaba a la señora XXXXX a realizar una importación ordinaria.

Sin embargo, esta postura fue rechazada y se elaboró un nuevo Acto Administrativo, el cual estuvo a cargo del doctor XXXXX, Jefe de la División Gestión Jurídica, quien realizando un estudio acucioso de la situación, entendiendo que la revocatoria del acto no iba encaminada a la anulación del “*Auto y Acta de Inspección*” No. 00050, sino al auto que ordenaba el decomiso⁹³, habida cuenta que este último, si cuenta con todas las características del acto administrativo, sin negar que el formulario de inspección fuere un documento público, por tanto, la decisión para derogar la actuación de la administración, sería únicamente en los presupuestos que llevaron a la confiscación de la mercancía.

Es por ello, que la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla ordenó la revocatoria parcial de la decisión de embargo de la mercancía, resolviendo la devolución de 3 artículos (campana extractora, campana metálica de 36”) que no sobrepasaran el cupo en dinero y cantidad de los exigidos en el equipaje no acompañado, pero confirmando el decomiso de los restantes 12 artículos que conformaban la cocina⁹⁴, estos avaluados en \$23’491.056 pesos colombianos, cantidad de objetos y de valor que sobrepasaban los límites establecidos en la norma aduanera.

⁸⁸ Ver folios 10 a 15

⁸⁹ Ver folio 12

⁹⁰ Ver folios 313 a 323

⁹¹ Ver folios 77 a 84 del Cuaderno Anexo No. 1

⁹² Ver folio 366

⁹³ Ver folio 314

⁹⁴ Ver folios 28 a 30 del Cuaderno Anexo No. 1

Así las cosas, tenemos que si bien la servidora acertó al momento de afirmar que el equipaje no acompañado de XXXXX podría ingresar al territorio nacional por esta modalidad, no es menos cierto que para los 15 objetos que conformaban la cocina, no era posible su importación por esta modalidad, pues, solamente se hubiera podido amparar el trámite de 3 artículos, por tanto, el hecho de aprobar el ingreso de la totalidad de las piezas, que conformaban un solo bien como lo es *cocina* tal como lo aludió la investigada, no hubiese sido posible de haberse consignado la información real en el documento “Auto y Acta de Inspección” de Equipaje No Acompañado No. 00050 del 28 de abril de 2013, en consecuencia, el Despacho no acoge esta tesis.

Respecto a las afirmaciones de XXXXX, quien manifestó que el pago del tributo único no era obligatorio, esta decantado en los párrafos que anteceden, cuáles son los requisitos que debe cumplir un equipaje para ser objeto de franquicia, por ello, esta insinuación por parte de la disciplinada, no tiene sustento alguno, al tener probado que se trató del ingreso de 15 piezas, valoradas en facturas por USD \$2.494 y, que por cuenta del proceso de fiscalización el valor se acercó a los USD\$8.000, por lo tanto la misma debió ser objeto de liquidación de un impuesto del 15% *ad valorem*, así las cosas para, esta Oficina de investigaciones disciplinarias, no resulta necesario realizar un estudio adicional y por ende, no será de recibo esta justificación. Para más claridad, se traerá a colación lo expuesto en la ley en este particular:

<<ARTICULO 208. EQUIPAJE CON PAGO DE TRIBUTO ÚNICO. Los viajeros que ingresen al país y acrediten una permanencia mínima en el exterior de cinco (5) días calendario, tendrán derecho a traer como equipaje acompañado o no acompañado, sin registro o licencia de importación y con el pago del tributo único de que trata el artículo 209o. del presente Decreto, hasta tres (3) unidades de cada uno de los siguientes bienes: artículos de uso doméstico sean o no eléctricos, artículos deportivos y artículos propios del arte u oficio del viajero, hasta por un valor total de dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 2.500) o su equivalente.

PARAGRAFO 1ro. Los viajeros que se acojan a lo dispuesto en el presente artículo, mantienen el derecho a la franquicia contemplada en el artículo anterior en la cuantía allí establecida (...)>>

La cantidad a la que se refiere el párrafo es de USD \$1.500⁹⁵, por lo tanto, es solamente hasta este valor que procede la omisión de liquidar el gravamen y su consecuente pago.

<<ARTICULO 209. LIQUIDACIÓN Y PAGO DE TRIBUTOS ADUANEROS POR CONCEPTO DE LA IMPORTACIÓN DE EQUIPAJES DE VIAJEROS. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 1742 de 1991, las mercancías que vengan en el equipaje de los viajeros provenientes del exterior y que no gocen de franquicia de gravámenes pagarán un tributo único del quince por ciento (15%) ad valorem.

El pago deberá efectuarse en los bancos o entidades financieras autorizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ubicados en los puertos o aeropuertos de arribo del viajero al territorio aduanero nacional>>

Sobre la presunta falla en el equipo de cómputo utilizado para elaborar el acta, manifestó que fue un error involuntario que se presentó al momento de diligenciar el formato conocido como “Auto y Acta de Inspección” para equipajes no acompañados, pues según aseveró el sistema no tomó la edición realizada, manteniendo los datos de una plantilla utilizada anteriormente.

Al respecto se considera que estas justificaciones no tuvieron en cuenta la realidad de la actuación y los efectos de la misma, ya que, en el eventual caso de ser cierta la falla en el computador, no podría ser que entre la plantilla del día 28 de abril de 2013 y el modelo editado del formato usado el 28 de diciembre de 2012, aparte de los datos generales de quien elabora el documento, tuviera

⁹⁵ Presidencia de la República, Decreto 2685 del 28 de diciembre de 1999, artículo 207 Sección X, Estatuto Aduanero. DO: 43.834

ÚNICAMENTE similitud en las casillas No. 19, 23, 32 y en las casillas de fecha de la declaración del viajero y del recibo de pago, por lo tanto, los demás espacios **SI TUVIERON** la información suministrada por la investigada.

Relacionado con el modelo utilizado el 28 de diciembre de 2012, este correspondió al No. 000191, elaborado por XXXXX, por cuenta de la operación de comercio exterior de la señora XXXXX⁹⁶, resultando entonces, en el conocimiento del modelo anterior y el resultado de su diligenciamiento, por tanto, la falla endilgada al computador utilizado, no tendría validez si se tiene en cuenta que, el documento final **SI TIENE MODIFICACIONES**, por tanto, no se explica como en la operación aduanera, al momento de diligenciar los campos, se hubiera guardado unos cambios si y otros no, situación no explicada por la servidora, que permite afirmar que la edición del documento y la información allí consignada, correspondió a la voluntad de la disciplinada.

En este sentido, este Despacho considera que, en caso de existir una falla de un equipo de cómputo o incongruencias al momento de trabajar con un modelo, no podría ser objeto de reproche por sí solo, sin embargo, no es factible alegarlo cuando en las casillas señaladas para liquidar el impuesto y en las observaciones, contienen información contraria a la verdad que favorecía a la usuaria aduanera y ello, produjo un resultado diferente al esperado de una funcionaria al servicio de la autoridad aduanera.

Adicionalmente, de tratarse de una falla como ella lo indica en su escrito, no se hubiera justificado en las omisiones de cobro del impuesto y también, manteniendo la teoría en la que XXXXX, podía ingresar la mercancía por esta modalidad, cuando está probado que no procedía la importación pretendida por la usuaria aduanera, por tratarse de elementos que excedían el cupo de equipaje no acompañado y acreditado el no pago de impuestos, esto último, probado conforme a los documentos existentes en el proceso de fiscalización **DM 201320130799**, ya que, en las resoluciones No. 778 del 17 de junio de 2013⁹⁷ (por medio de la cual se ordenó el decomiso de la mercancía) y No. 243 del 5 de febrero de 2014⁹⁸ (acto administrativo que resolvió una solicitud de revocatoria directa).

Y es que precisamente estas decisiones, se produjeron en consecuencia a las inconsistencias en el "*Auto y Acta de Inspección*" del 28 de abril y esta, que fue diligenciada con información contraria a la verdad, tuvo como responsable a la servidora XXXXX.

Este análisis conllevaría entonces a que, se determine que la mencionada falla del computador, no fue tal, por el contrario, se trató de un diligenciamiento acomodado de la servidora XXXXX, para favorecer a la señora XXXXX con el no pago del tributo que daba lugar su mercancía. Por estas razones, la falla del computador no se entiende como tal y este Despacho mantiene su apreciación sobre el mismo.

Finalmente, la servidora XXXXX, acusó también la falta de inducción para llevar a cabo sus funciones, sobre esto, el Jefe de Personal (A), por medio del oficio **No. 1-87-201-401-0323 del 14 de julio de 2017**⁹⁹, certificó que la servidora no había participado en jornadas de capacitación para el mes de abril de 2013, periodo de tiempo solicitado por la investigada en su escrito de descargos.

Sin embargo, pese a este documento, este Despacho debe mencionar que el servidor XXXXX quien fuera Jefe de la encartada, en su declaración juramentada se refirió a la forma en la cual inician sus

⁹⁶ Ver folio 309

⁹⁷ Ver folio 242 a 249

⁹⁸ Ver folios 313 a 323

⁹⁹ Ver folio 224

actividades los funcionarios adscritos al Grupo Informal de Viajeros, puesto que afirmó: “...Claro que sí, ya que cada uno de los funcionarios que van llegando se les realiza una inducción y creo que, para la fecha indicada, era por el término de una semana, y allí mismo, se le indican las normas que reglamentan el régimen de viajeros e incluso, se le entregan folletos donde se indican cada uno de los procesos que allí se manejan” (subrayado fuera de texto)

En la misma línea agregó: a todos y cada uno de los funcionarios que van ingresando, por parte del suscrito, se le da instrucciones de acuerdo a la reglamentación del régimen de viajeros y, además, se invitan a las capacitaciones que se imparten a las líneas aéreas y demás autoridades que operan en el Aeropuerto, que están establecidos en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Soledad, Atlántico. Además, podemos agregar, que el Grupo recibía capacitaciones de otros funcionarios de esta misma Dirección en la medida que se solicitaba por parte de la jefatura del grupo, donde participaban todos los funcionarios” (subrayado fuera de texto).

De este testimonio se colige que, si el Jefe del Grupo de trabajo afirma la existencia de un plan de entrenamiento para los servidores, no puede ser de recibo para este Despacho que la funcionaria desconociera este hecho y pretendiera justificar sus actuaciones por la falta de capacitaciones en el mes de ocurrencia de los mismos, además, se debe tener en cuenta que XXXXX, en el mes de diciembre del año 2012, elaboró un “Auto y Acta de Inspección” de Equipaje no Acompañado, el cual no registra incongruencias y esto correspondería, a que la aquí disciplinada conoce de antemano el procedimiento y sus características particulares.

En consecuencia, a pesar de tratarse de capacitaciones en lugar de trabajo y sin que hubiere registro de las mismas, este Despacho encuentra probado que XXXXX, si conocía sus funciones y las realizaba de manera cotidiana sin que hubiere asomo de falta de pericia, por tanto, si contaba con la capacitación y la experticia necesaria para ejecutar el 28 de abril de 2013, una labor acorde con su rol de servidora pública.

7.6.2. De los alegatos de conclusión presentados por la doctora XXXXX:

La profesional del Derecho, de conformidad con lo establecido en el numeral 8 artículo 92 del CDU, presentó escrito de conclusión en términos, prueba de ello, es el correo electrónico enviado el 10 de enero¹⁰⁰ del presente año.

En ese orden de ideas, la apoderada de la servidora XXXXX, realizó un análisis de las pruebas allegadas al expediente y mencionó los aspectos que en su criterio este Despacho no tuvo en cuenta al momento de proferir los cargos y que infiere, serian de suma relevancia para llegar a la absolución de su representada. Bajo ese aspecto, centro su atención en explicar lo siguiente:

- *Se trató de un error involuntario de XXXXX, que se adecua a lo contemplado en el numeral 6° del artículo 28 del CDU “Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria”.*

Bajo este contexto, la profesional del Derecho hizo alusiones a presuntas fallas en el procedimiento de avalúo de la mercancía, situación que corresponde al consorte a la DIAN, entidad que ya se pronunció sobre este procedimiento de importación a través de la resolución No. 243 del 5 de febrero de 2014¹⁰¹, ordenando la revocatoria parcial de Auto que ordenó en el decomiso y de esta

¹⁰⁰ Ver folio 431

¹⁰¹ Ver folios 313 a 323

manera, dispuso de la devolución de 3 elementos cuyos valores individuales o en suma total, no superara el monto de **USD \$2.500**, sin embargo, precisó que para realizar la entrega de la mercancía, se debía pagar el tributo correspondiente.

Por esta razón, lo concerniente al proceso **DM 2013 2013 0799** surgido con ocasión al decomiso de la mercancía a la señora XXXXX, no será objeto de debate de legalidad en sede disciplinaria.

Ahora bien, respecto a las afirmaciones de la doctora XXXXX, de las cuales, a pesar de ser ambiguas, conforme a la petición realizada en su escrito de conclusión, justificó las acciones de su poderdante al estar bajo un eximente de responsabilidad, por lo tanto, este Despacho hará un estudio sobre el error invencible aludido.

En ese sentido, inicialmente se debe traer a colación lo señalado por los doctores XXXXX y XXXXX¹⁰², señalan que: *“Esta causal de justificación de la conducta contemplada en el numeral 6° del artículo 28 del Código Disciplinario Único, error invencible; con la convicción de que en su acción no concurre alguno de los elementos que de manera real se estructuran”*

En lo que corresponde a la definición del error disciplinario, los autores refieren que *“en materia disciplinaria se presenta cuando existe una disparidad entre la conciencia del autor y la realidad, aspecto, al cual debe sumarse el hecho de que el error sea vencible o invencible, pues dependiendo de ello, es posible considerarlo o no como un eximente de responsabilidad”*

Concordante a lo enunciado, se tiene que la máxima autoridad disciplinaria ha manifestado que *“En efecto, el error invencible supone que la persona ha empleado todos los medios necesarios para tener el conocimiento del hecho del hecho del cual predica el error; es decir que, a pesar de informarse y verificar la información, que no se logre tener conocimiento cierto del hecho. En este caso, se trata de un error no superable que conduce a la causal de exclusión de responsabilidad. En el caso contrario; esto es, cuando el error es vencible o superable, no es posible aducirlo como un eximente de responsabilidad¹⁰³”* (subrayado fuera del texto).

De igual forma, ha de indicarse que, no basta la simple afirmación de que se está frente a un eximente de responsabilidad para que este se entienda configurado, toda vez que resulta necesario entrar a analizar las circunstancias que rodean el hecho del cual se predica el error y las condiciones de la persona en la que se pretende aducir a su favor.

Ha de aclarar este Despacho, que la representante de la disciplinada adujo un error invencible y este lo asoció a la falla del computador al momento de registrar los datos de la operación de comercio exterior. En consecuencia, esa Subdirección analizará lo acusado desde la perspectiva del error invencible asociado al equipo de cómputo.

Inicialmente, como ya se probó a través del al acta de posesión No. 010 del 3 de enero del año 2012¹⁰⁴, la servidora XXXXX, se encontraba vinculada a la DIAN desde el año 2008¹⁰⁵ y para la época de los hechos, fungía como funcionaria de la División de Gestión de la Operación Aduanera.

Ahora bien, desde la tesis señalada por la defensa, en la que refiere a la existencia de un error invencible en el momento de los hechos, asociando este a la falla del computador que se utilizó al

¹⁰² MEJÍA OSSMA, J. & QUIÑONES RAMOS S. SM. (2004), Procedimiento Disciplinario, capítulo VI Causales de exclusión de responsabilidad (Pág. 219). Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley

¹⁰³ Procuraduría General de la Nación, Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública radicado IUC 2011-104376837

¹⁰⁴ Ver folio 40

¹⁰⁵ Ver folio 50

momento de elaborar el “Auto y Acta de Inspección” No. 000050 del 28 de abril de 2013, anticipadamente esta oficina de investigaciones disciplinarias, no acogerá los argumentos de la defensa, conforme se pasa a exponer:

Como se puede inferir de las definiciones del tipo de error que eximen de responsabilidad disciplinaria, porque se debe establecer si efectivamente la falla que presentó el equipo de cómputo, configura un error invencible, tal como lo quiso argumentar la defensa, sin embargo, en estas afirmaciones de la apoderada judicial, desconoció que la investigada fue quien registró unos datos falsos en el documento de inspección, hecho que en consecuencia, favoreció el ingreso de mercancía sin el lleno de los requisitos exigidos por la legislación aduanera, en vez de eso, atacó el hecho de la falla presentada y los pormenores del proceso de fiscalización, sobre este último, es claro que la legalidad del mismo no se discute en un proceso disciplinario.

Ya en materia, el error invencible es un hecho que sucederá así el agente tuviera todos los recaudos en la operación, sería una situación no predecible para el servidor que contara con el conocimiento necesario y la praxis adecuada, sin embargo, como se observa en el material probatorio, los documentos soporte mencionaban una cantidad de piezas que claramente superaban las 3 unidades permitidas por la modalidad, las facturas sumaban un valor superior a los USD \$ 1.500 razón para liquidar el tributo único y además, la servidora ya había adelantado una diligencia de estas, tal como se puede establecer en su participación en la elaboración del “Auto y Acta de inspección” No. 000191 del 28 de diciembre de 2012¹⁰⁶. Este documento, fue ignorado por la defensa a lo largo de su escrito, pero en él, se prueba que la servidora contaba con la experiencia e idoneidad para llevar a cabo una revisión de mercancía enviada como equipaje no acompañado.

De este modo, la investigada no se encontraba amparada en la causal eximente de responsabilidad establecida en el numeral 6° del artículo 28 del CDU, pues si hubiese hecho una lectura de los artículos correspondientes a la reglamentación de la importación a través de la modalidad de equipaje no acompañado, contenida en la Sección X del Decreto 2685 de 1999 y concordantes, habría concluido fácilmente que un viajero que trajera mercancía como la expuesta por la señora XXXXX, no le era permitida dicha importación por exceder los topes de la misma.

Además, de acuerdo con el extracto de hoja de vida de la señora XXXXX, quien estaba vinculada a la División de la Gestión de la Operación Aduanera desde el año 2012 y que el día 29 de diciembre de 2012 elaboró un “Auto y Acta de inspección”, en razón a las reglas de la experiencia, prueban que contaba con el entendimiento suficiente para determinar una consecuencia al incluir información falsa en un documento público y que ello, conllevara a favorecer a la usuaria aduanera con la exoneración del pago del tributo único correspondiente.

Lo anterior, para señalar que, debido a su conocimiento de la reglamentación, además de su práctica laboral, no conllevaría a que se pudiese amparar en el principio de buena fe para justificar su actuación, pues contaba con todos los elementos para salir de su error. Es importante destacar que, como se aludió previamente, sobre los servidores públicos recae una obligación especial de reconocer sus deberes y responsabilidades independiente de la profesión.

En consecuencia, no puede la defensa mencionar que la servidora habría ocupado cargos meramente secretariales para justificar un presunto desconocimiento de las normas aplicables a la modalidad de importación, pues sobre el particular el Consejo de Estado manifestó: “En este estado, no comparte la Sala el argumento que trae a colación el actor en el sentido de que ni la Constitución, ni la ley ni el decreto reglamentario de su función, le exigían obligatoriamente

¹⁰⁶ Ver folio 309

conocer la normativa de la institución en la que labora, además de que su formación lo era en las ciencias de la salud y no en las jurídicas; **porque no puede olvidarse, que la responsabilidad de todo servidor público en materia disciplinaria encuentra fundamento, en el postulado superior contenido en el artículo 6º de la Carta Política, que se constituye en el cimiento de sus obligaciones y deberes. En efecto, este precepto dispone, que los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. De suerte que, cuando la Carta Fundamental y las leyes ordenan al servidor público cumplir con ellas, se entiende que así deben hacerlo, acatando en particular, las normas que regulan específicamente su actividad, sin omitir nunca ningún procedimiento ni extralimitarse en el cumplimiento de sus funciones so pena de ser merecedor de las sanciones correspondientes**¹⁰⁷". (Subrayado y negrillas fuera del texto)

La jurisprudencia del órgano de cierre en lo contencioso administrativo, menciona entonces que los funcionarios públicos deben cumplir **TODO EL MARCO NORMATIVO** que regule su actividad, en este sentido, no debe desconocerse lo afirmado por el servidor XXXXX¹⁰⁸, quien fuere el Jefe del Grupo informal de viajeros, quien aludió que, al inicio de toda actividad con un funcionario nuevo, se le realiza una inducción y se le indican las normas que reglamentan el régimen de viajeros y para este caso, teniendo en cuenta el antecedente del mes de diciembre de 2012, es diáfano para este Despacho que XXXXX conocía su cargo y entendía las funciones que realizaba.

En mérito de lo anterior, esta oficina de investigaciones disciplinarias, establece que no se hizo presente la causal eximente de responsabilidad, toda vez que, conforme lo expuesto, la servidora contaba con los elementos normativos para negar el ingreso al país de la mercancía y además, de poder subsanar los errores en el "Auto y Acta de inspección", sin embargo, pese hacerse notorias las incongruencias legales y formales al momento de realizar la operación aduanera, accedió a otorgar levante a la mercancía, diligenciando con datos falsos el "Auto y Acta de inspección" No. 00050 del 28 de abril de 2013.

8. CALIFICACIÓN DE LA FALTA

En el Auto de cargos No. 17406-00007 del 16 de marzo de 2017, dentro del cual se profirieron los cargos a las disciplinada, se imputó provisionalmente la comisión de la falta como GRAVÍSIMA, en cuanto constituye la realización de una conducta contemplada en el Numeral 1 del Artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

Luego de agotadas las etapas del proceso disciplinario adelantado y del recaudo probatorio, concluye este despacho que las conductas reprochadas a la inculpada XXXXX, realmente fueron por ella cometidas y, en efecto, como se calificó en la precitada providencia, corresponde a la tipología de las faltas que por expresa disposición legal fueron consagradas como **GRAVÍSIMAS**.

Sobre este punto, conforme a los lineamientos expuestos al respecto por la Corte Constitucional en la sentencia C-181 de 2002, este tipo de faltas no requieren estudio o análisis de graduación y, por ende, para los fines propios de esta providencia atendiendo al expreso y taxativo mandato legal será tenida en cuenta como **GRAVISIMA**:

"FALTA DISCIPLINARIA - Sistema de graduación no opera en la de carácter gravísimo. (...) en tratándose de las faltas que han sido catalogadas como gravísimas por expresa denominación legal, el sistema de

¹⁰⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, C.P. Dr.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Sentencia de 19 de abril de 2012, Expediente No. 52001-23-31-000-2006-00660-01 (06662008), Actor: Carlos Alberto Aguirre Cortés

¹⁰⁸ Ver folios 277 a 285

graduación del artículo 27 no opera. En otras palabras, y de acuerdo con la providencia en cita, el hecho de que los criterios para determinar la gravedad de las faltas disciplinarias sólo se apliquen a las faltas graves o leves, mas no a las gravísimas, se encuentra ajustado a las prescripciones de la Carta Fundamental. (...) Como ya se dijo, son precisas las conductas que se encuentran estatuidas como faltas gravísimas, respecto de las cuales no cabe ningún tipo de gradación (arts. 25 y 26)."

La consideración anterior se justifica, dice la Corporación, ya que el legislador es autónomo para definir, dentro de los márgenes de lo razonable, los criterios aplicables al ejercicio de la potestad sancionatoria del Estado (...)

Sin que sea necesario hacer comentario adicional a la enfática consideración de la Corte, esta Corporación se estará a lo resuelto en la Sentencia C-708 de 1999109 (confirmada en la Sentencia C-292 de 2000) respecto de la constitucionalidad de los apartes subrayados de los artículos 27 de la Ley 200 de 1995 pues, contrario a lo sostenido por el actor, las faltas gravísimas, cuando su comisión ha sido comprobada y adjudicada a título de dolo o culpa, no son susceptibles de graduación para efectos de determinación de la sanción."

Así las cosas, se tiene que la conducta reprochada a la disciplinada es de aquellas que el propio legislador instituyó como GRAVISIMA, ninguna determinación diferente en cuanto a la gravedad de la falta puede hacer este censor.

9. DE LA SANCION POR IMPONER

Demostrado quedó en el presente proceso que la investigada XXXXX, para la época de los hechos que se investigan prestaba sus servicios como Facilitador IV Nivel 104 Grado 0, ejerciendo funciones en el Grupo Informal de Viajeros, de la División de Gestión de la Operación Aduanera de la Seccional de Aduanas de Barranquilla, es responsable de cometer las faltas disciplinarias **GRAVÍSIMA** contenidas en el numeral 1° y 44° del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

Consecuentemente, configurados los presupuestos legales exigidos por el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, al obrar en el proceso prueba acerca de la certeza de la existencia de la falta y de la responsabilidad de la involucrada, es menester proceder a determinar la sanción a imponer, para lo cual se partirá de los siguientes presupuestos:

La conducta cometida por el disciplinado fue determinada como **FALTA GRAVISIMA DOLOSA**, cuya sanción está establecida en el artículo 44 del Código Disciplinario Único, así:

<<Artículo 44. Clases de sanciones. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones:

1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima. (...)>>

Respecto al término de inhabilidad general, el artículo 46 de la Ley 734 de 2002 establece que debe graduarse dentro de unos rangos preestablecidos de la siguiente manera:

"Artículo 46. Límite de las sanciones. La inhabilidad general será de diez a veinte años, pero cuando afecte el patrimonio económico del Estado la inhabilidad será permanente (...)

Aclarado lo anterior, al tenor del artículo 47 de la ley disciplinaria que fija los criterios a tener en cuenta para determinar el término de duración de la destitución, este despacho encuentra necesario tener en cuenta que la procesada no ha sido sancionada disciplinariamente y que al momento de la comisión de la falta no pertenecía al nivel directivo o ejecutivo de la entidad, así que, a pesar de lo reprochable de su conducta, no se afectaron derechos fundamentales; circunstancias que serán evaluadas en su favor.

En conclusión, en ejercicio del principio de la proporcionalidad, debe imponerse a la disciplinada XXXXX, sanción disciplinaria consistente en **DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL PARA EJERCER FUNCIONES PÚBLICAS POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS**, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive del presente proveído.

Finalmente, frente a las nulidades incoadas a través de alegatos de conclusión, y su rechazo en la parte inicial de esta resolución, se debe indicar, que por tratarse de un de un solo acto decisorio y de fondo (Fallo de Primera Instancia), resulta inocuo y procesalmente ilógico, correr traslado para la presentación y sustentación de un eventual recurso de reposición, debiendo ser ventilada cualquier inconformidad en torno a la decisión en comento, en armonía con los argumentos expuestos mediante alzada, en caso de considerar pertinente su exposición.

Así las cosas, hablar aquí de un recurso de reposición, sería manifiestamente inane, ya que esto conllevaría necesariamente al estudio por parte del operador de primera instancia, a revisar la legalidad de una decisión ya fallada y cuyo único escenario de controversia, por tratarse de una etapa perentoria, solo podría activarse mediante el recurso de apelación ante la Segunda Instancia.

10. OTRAS CONSIDERACIONES.

Habida cuenta de que los hechos que fueron materia de esta actuación, comportan también una conducta punible, se ordenará la compulsa de copias a fin de que desde la perspectiva penal se investigue, en caos de considerarlo pertinente, la **FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO**; copias que deberán ser remitidas a la autoridad competente, específicamente a la Oficina de Asignaciones respectiva a la Fiscalía General de la Nación Seccional Atlántico.

En mérito de lo expuesto, el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA de XXXXX, identificado con la cédula de ciudadanía número XXXXX, por la conducta consignada como cargo en el Auto número 17406-0007 del 16 de marzo de 2017; actuar constitutivo de falta disciplinaria al tenor de lo dispuesto en el artículo 48 numeral 44°.

SEGUNDO: DECLARAR LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA de XXXXX, identificado con la cédula de ciudadanía número XXXXX, por la conducta consignada como cargo en el Auto número 17406-0007 del 16 de marzo de 2017; actuar constitutivo de falta disciplinaria al tenor de lo dispuesto en el artículo 48 numeral 1°, al tenor de lo decidido en la presente resolución.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, **IMPONER** a XXXXX, sanción disciplinaria consistente en **DESTITUCIÓN EN EL EJERCICIO DEL CARGO E INHABILIDAD GENERAL POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS**, de conformidad con lo señalado en la parte motiva precedente.

CUARTO: NOTIFICAR PERSONALMENTE la presente decisión de conformidad con lo establecido en el artículo 101 y 107 de la Ley 734 de 2002, a la Abogada XXXXX, quien reportó como dirección procesal la Carrera 44C No. 22-72 apartamento 604 de Bogotá D.C; a la investigada XXXXX, quien se podrá ubicar en la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla.

QUINTO: ADVERTIR que contra la presente decisión procede el **RECURSO DE APELACIÓN**, en los términos de los artículos 112, 115 y 119 de la Ley 734 de 2002.

SEXTO: En firme la presente decisión, **COMUNICARLA** en la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con el artículo 174 del Código Disciplinario Único.

SEPTIMO: COMPULSAR copias de la presente decisión en los términos señalados en el acápite de otras consideraciones.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE,

JORGE ADRIANO MORENO PONCE
Subdirector Técnico de Agencia Investigaciones Disciplinarias
UAE Agencia ITRC